

제10장

공동소송

제1절 총 설 388

제2절 통상공동소송 389

제3절 필수적 공동소송 394

제4절 예비적·선택적 공동소송 405

제1절 총 설

1. 의 의

‘공동소송’이란 하나의 소송절차에서 원고 또는 피고의 어느 한쪽이나 양 쪽이 여러 사람인 경우를 말한다. 이 경우에 여러 사람인 원고 또는 피고를 공동원고 또는 공동피고라고 하고, 단순히 공동소송인이라고도 한다. 동일한 당사자 사이에서 하나의 소로써 여러 개의 청구를 하는 경우를 소의 객관적 병합이라 함에 대하여 공동소송은 소의 주관적 병합이라 한다.

2. 종 류

공동소송은 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 공동소송인지 여부에 따라 통상공동소송과 필수적 공동소송의 두 가지로 분류되고, 특수한 형태의 공동소송으로 예비적·선택적 공동소송이 있다.

‘통상공동소송’이란 공동소송인과 상대방 사이의 청구가 각기 별개 독립의 것이어서 반드시 일률적으로 승패를 확정할 필요가 없고 각 공동소송인에 대하여 판결 결과가 구구하게 나와도 무방한 성질의 사건이 단지 서로 일정한 관련이 있기 때문에 편의상 하나의 소송절차에 의하는 공동소송 형태를 말한다.

‘필수적 공동소송’이란 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 경우의 공동소송을 말한다(민소 67조). 공동소송인 모두에 대하여 분쟁을 일률적으로 해결하여야 하기 때문에 공동소송인 사이에 소송의 승패가 통일적으로 결정되어야 하고 각각 다르게 되는 것이 법률상 허용되지 않는 경우이다. 필수적 공동소송은 고유필수적 공동소송과 유사필수적 공동소송으로 분류된다.

‘예비적·선택적 공동소송’이란 공동소송인 가운데 일부의 청구가 다른 공

동소송인의 청구와 법률상 양립할 수 없거나(공동원고인 경우), 공동소송인 가운데 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 양립할 수 없는 경우(공동피고인 경우)의 공동소송을 말한다(민소 70조).

3. 발생원인 및 소멸원인

가. 발생원인

(1) 원시적 발생원인

처음부터 여러 사람의 원고가 또는 여러 사람의 피고에 대하여 공동으로 제소한 경우이다. 이를 소의 고유의 주관적 병합이라 한다.

(2) 후발적 발생원인

처음에는 원고와 피고가 각 한 사람씩인 소송형태였으나, 소송 도중에 공동소송형태로 되는 경우이다(예: 민소 68조, 82조, 83조, 141조, 민집 249조 2항).

나. 소멸원인

통상공동소송의 경우에 공동소송인 중 일부의 소송관계가 일부판결, 일부화해, 청구의 포기·인낙 또는 일부취하에 의하여 종료되는 때, 또는 민사소송법 141조에 의하여 변론이 분리된 때에는 공동소송은 단일의 소로 변모하게 된다. 그러나 필수적 공동소송의 경우에는 일부판결, 일부화해, 변론의 분리 등이 모두 금지된다.

제2절 통상공동소송

1. 총설 - 공동소송인 독립의 원칙

통상공동소송은 원래 개별적·상대적으로 해결하여야 할 여러 개의 사건이 편의상 하나의 소송절차에 병합된 소송형태이기 때문에, ① 공동소송인

가운데 한 사람의 소송행위 또는 이에 대한 상대방의 소송행위(청구의 포기·인낙, 화해, 자백, 상소, 소 또는 상소취하, 공격방어방법 제출 등), ② 공동소송인 가운데 한 사람에 관한 사항(중단·중지사유 발생, 기일에 출석하지 아니한 효과의 발생, 상소기간 등) 등은 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 아니한다(민소 66조).

이와 같이 통상공동소송에 있어서 각 공동소송인은 다른 공동소송인에 의한 제한이나 간섭을 받지 않고 각자 독립하여 소송을 수행하는데 이를 ‘공동소송인 독립의 원칙’이라고 한다.

2. 요건

가. 주관적 요건

공동소송이 인정되면 여러 사람의 당사자를 하나의 소송절차에 관여시키게 되므로, 이를 정당화할 만한 타당성·합리성이 있어야 한다. 이를 주관적 병합요건이라 하는데 이에 관해서는 민사소송법 65조가 규정하고 있다.

(1) 소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 공통되는 경우(민소 65조 전문 전단)

공유자들이 공유물의 인도청구소송을 제기하는 것은 그 물건에 대한 권리를 공통으로 가지는 경우이다. 채권자가 여러 사람의 연대채무자에게 연대채무지급청구를 하는 경우는 의무 공통에 해당한다. 이는 소송목적인 청구 자체가 서로 공통성을 갖고 관련되어 있는 경우이다.

(2) 소송목적이 되는 권리나 의무가 사실상 또는 법률상 같은 원인으로 말미암아 생긴 경우(민소 65조 전문 후단)

같은 사고에 기한 여러 피해자의 손해배상청구(같은 사실상 원인에 기인한 것), 주채무자와 보증인에 대한 지급청구(같은 법률상 원인에 기인한 것)와 같이 청구권 자체는 각각 독립적이지만 그 발생원인이 공통된 경우이다. 동일한 부동산에 관하여 순차로 마쳐진 소유권보존등기와 소유권이전등기의 등

기명의인을 상대로 소유권보존등기의 원인무효를 이유로 제기하는 각각의 말소등기절차 이행청구도 여기에 해당한다.

(3) 소송목적이 되는 권리나 의무가 같은 종류이며, 사실상 또는 법률상 같은 종류의 원인으로 말미암은 것인 경우(민소 65조 후문)

앞서 본 두 가지 경우와 달리 각 청구 상호 간에 구체적 관련성을 요구하는 것이 아니기 때문에 그보다 요건이 완화되어 있다고 할 수 있다. 하나의 보험회사가 여러 보험가입자를 상대로 보험료의 지급을 구하는 소, 여러 건물을 임대한 한 사람의 임대인이 각각의 임차인을 상대로 건물인도를 구하는 소와 같이 청구권 상호 간에는 아무 관련이 없으나 청구권의 성격이 같은 종류이고, 발생원인도 같은 종류인 경우이다.

나. 객관적 요건

공동소송은 공동소송인과 상대방 사이에 별개의 청구가 병합되므로 다음과 같은 청구의 병합요건을 갖추어야 한다.

- (1) 공동소송인의 각 청구가 같은 종류의 소송절차에 의해 심리할 수 있을 것
- (2) 각 청구에 대하여 공통의 관할권이 있을 것

민사소송법 65조 전문에 해당하는 경우에만 25조 2항의 관련재판적이 인정되므로, 65조 후문의 경우에는 25조 2항이 적용되지 않고 별도의 규정에 따라 공통의 관할권이 인정되어야 한다.

다. 요건의 심사

공동소송의 객관적 요건은 직권으로 조사하여야 하나 주관적 요건은 직권 조사사항이 아니다. 따라서 피고의 이익을 기다려 조사하여야 하고 피고의 이익 없이 응소하면 주관적 요건의 흠이 있어도 공동소송이 허용된다. 피고의 이익이 있어 조사 결과 그 요건의 흠이 있는 것으로 판명되어도 법원은 공동소송을 각하하는 것이 아니라 소송을 분리하여 별개의 소로 각각 심리

하여야 한다.

3. 내 용

통상공동소송에서 공동소송인은 각자 독립하여 소송대리인을 선임할 수 있고, 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해도 각자 할 수 있으며, 상대방의 주장사실에 대하여 각자 다투거나 자백할 수 있다. 심리의 시작도 모든 공동소송인에 대하여 일률적으로 같은 기일에 진행되어야 하는 것은 아니고, 소장부분이 송달불능된 일부 공동소송인에 대한 관계에서는 변론을 분리하여 주소보정을 명하고, 적법하게 송달된 나머지 공동소송인에 대하여만 심리를 시작하여도 무방하다.

공동소송인 가운데 한 사람은 자기의 주장사실에는 관계가 없고 다른 공동소송인의 이해에 관계되는 사항에 대하여 다른 공동소송인의 소송에서 증인으로 신문받을 수 있다. 그러나 공동소송인은 자신의 소송과 이해관계 있는 사항에 대하여는 다른 공동소송인을 위하여 증인이 될 수 없다.

어느 한 사람에 대해서만 변론을 분리하고 일부판결을 할 수도 있으며, 판결 결과가 일률적일 필요도 없다. 상소에 의한 확정차단 및 이심의 효력은 여러 사람에 대한 전부판결의 경우에도 상소인과 그 상대방에 대해서만 생긴다.

그러나 공동소송인은 각자 독립의 지위를 갖지만 같은 절차에서 병합 심리되는 이상, 각 공동소송인에 대하여는 기일을 공통으로 지정하고, 변론이나 증거조사도 공통으로 실시하며, 1개의 전부판결을 하는 것이 원칙이다. 이에 따라 실제로는 공동하여 주장 또는 증거제출을 하는 수가 많으며, 사실상 소송진행도 같이 하게 되어 소송경제나 재판의 통일을 기할 수 있게 된다.

4. 공동소송인 독립의 원칙에 대한 예외 - 증거공통의 원칙

공동소송인 독립의 원칙을 관철하면 각자 독립하여 소송을 수행하기 때문

에 공동소송인마다 구구한 결론이 나오게 되고, 실질적인 하나의 사건에 관하여 공동소송인 사이에 재판의 통일이 보장되지 않는다. 다만 그에 대한 예외로서 공동소송인 사이에 주장공통의 원칙과 증거공통의 원칙이 적용되는지 문제 된다.

공동소송에 있어서 ‘증거공통의 원칙’이란 공동소송인 가운데 한 사람이 제출한 증거는 다른 공동소송인에 관련된 다툼이 있는 사실에 대해서 그의 원용에 관계없이 공통된 사실인정의 자료로 할 수 있다는 것을 말한다. 공동소송인 간의 증거공통의 원칙에 관하여 판시한 판례는 없으나(공동소송인 간 이 아니라 당사자 사이에 증거공통의 원칙이 적용된다는 점에 대하여는 대법원 2004. 5. 14. 선고 2003다57697 판결 등이 있다) 이에 따르는 것이 실무이고, 통설도 이를 긍정한다. 그러나 공동소송인 상호 간 이해가 상반되거나 명시적인 반대의사가 표시된 경우는 이 원칙이 적용되지 않는다고 한다.

다만 자백한 공동소송인에 대하여는 증거조사결과 얻은 심증에도 불구하고 자백한 대로 사실 확정을 해야 하므로 증거공통의 원칙에도 불구하고 자백한 자에 대한 사실 인정과 자백하지 아니한 자에 대한 사실 인정이 다를 수 있다. 공동소송인 중 1인의 자백은 변론 전체의 취지로서 평가될 수 있을 뿐이다(대법원 1976. 8. 24. 선고 75다2152 판결).

한편 공동소송에서 ‘주장공통의 원칙’이란 공동소송인 가운데 한 사람의 주장사실은 다른 공동소송인에도 영향을 미치고 그의 원용에 관계없이 그를 위해서도 주장된 것으로 할 수 있다는 것을 말한다. 공동소송인 독립의 원칙에 대한 예외로서 주장공통의 원칙을 긍정할 것인가에 관하여 학설이 나뉘어 있지만, 판례는 공동소송인 가운데 한 사람이 상대방의 주장사실을 다투며 항변하는 등 다른 공동소송인에게 유리한 행위를 한 경우라도 다른 공동소송인이 이를 원용하지 않는 한 그에 대한 효력이 미치지 않는다고 하여 공동소송인 간의 주장공통의 원칙을 부정하고 있다(대법원 1994. 5. 10. 선고 93다47196 판결).

따라서 예컨대 주채무자와 그 보증인을 공동피고로 하여 대여금청구를 한 경우에, 주채무자의 변제항변을 받아들여 주채무자에 대한 청구를 기각하더라도 보증인이 변제항변을 하지 아니하면 그로 인한 혜택을 받을 수 없어 보증인에 대하여는 원고의 청구를 인용하게 된다. 이와 같이 통상공동소송에서는 공동당사자들 상호 간의 공격방어방법의 차이에 따라 모순되는 결론이 발생할 수 있고, 이는 변론주의를 원칙으로 하는 소송제도 아래서는 부득이한 일로서 판결의 이유모순이나 이유불비가 된다고 할 수 없다(대법원 1991. 4. 12. 선고 90다9872 판결).

제3절 필수적 공동소송

1. 총 설

통상공동소송에서는 여러 소송의 결합관계가 느슨하여 각 소송이 독자적으로 병존하지만, 이러한 독립성이 소송법상 또는 실체법상의 이유에 의하여 배제되는 경우가 있는데, 이것이 바로 필수적 공동소송이다. 필수적 공동소송이란 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 경우의 공동소송을 말한다(민소 67조). 공동소송인 모두에게 분쟁을 일률적으로 해결하여야 하기 때문에 공동소송인 사이에 소송의 승패가 통일적으로 결정되어야 하고 구구하게 되는 것이 법률상 허용되지 않는 경우이다.

필수적 공동소송은 고유필수적 공동소송과 유사필수적 공동소송으로 분류된다.

2. 고유필수적 공동소송

가. 의 의

‘고유필수적 공동소송’이란 소송의 공동이 법률상 강제되고 또 공동소송

인 모두에게 합일확정의 필요가 있는 공동소송을 말한다. 따라서 단독소송이 허용되지 않고 반드시 전원이 공동소송을 하여야 비로소 당사자적격이 인정되고, 고유필수적 공동소송이 모든 관계자에 의하여 또는 모든 관계자에 대하여 제기되지 않은 경우에는 부적법 각하된다.

고유필수적 공동소송의 범위에 관하여는 여러 사람에게 관리처분권이 귀속되는지 여부를 기준으로 판단하는 관리처분권설이 통설인데, 이에 따르면 결국 고유필수적 공동소송은 실체법상 관리처분권(소송수행권)이 여러 사람에게 귀속되는 경우의 공동소송이라 할 수 있다.

나. 고유필수적 공동소송에 해당되는 경우

(1) 형성권이 여러 사람에 의하여 또는 여러 사람에 대하여 행사되어야 할 경우 타인 사이의 권리관계의 변동을 목적으로 하는 형성의 소(또는 이와 동일시할 확인의 소)에 있어서는 원칙적으로 그 권리관계의 주체인 사람 모두를 공동피고로 하여야 한다.

공유물분할청구는 분할을 구하는 공유자가 다른 공유자 모두를 공동피고로 하여야 하고(대법원 2014. 1. 29. 선고 2013다78556 판결), 인접하는 토지의 한편 또는 양편이 여러 사람의 공유에 속하는 경우에 그 경계의 확정을 구하는 소송은 관련된 공유자 전원이 공동하여서만 제소하고 상대방도 관련된 공유자 전원이 공동으로서만 제소될 것을 요건으로 하며(대법원 2001. 6. 26. 선고 2000다24207 판결), 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 24조 3항(현행 법률 24조 5항에 해당한다)에서 정한 관리인 해임의 소는 관리단과 관리인 사이의 법률관계 해소를 목적으로 하는 형성의 소이므로 법률관계의 당사자인 관리단과 관리인 모두를 공동피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다(대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결).

제3자가 제기하는 혼인무효·취소의 소는 부부를(가소 24조 2항, 대법원 1965. 10. 26. 선고 65므46 판결), 제3자가 제기하는 친자관계부존재확인

소는 생존 부모 및 자를(대법원 1983. 9. 15. 자 83즈2 결정), 공동피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이다.

(2) 재산권 또는 관리처분권이 여러 사람에게 합유적 또는 총유적으로 귀속된 경우

(가) 재산권이 합유인 경우

합유자 개개인에게 관리처분권이 없는 합유의 경우가 이에 해당한다. 즉 합유물을 처분 또는 변경합에는 합유자 전원의 동의가 있어야 하며 전원의 동의가 있어야 지분처분권을 갖게 되므로(민법 272조, 273조), 합유물에 관한 소송은 원칙적으로 고유필수적 공동소송이 된다. 신탁법 50조는 수탁자가 여럿인 경우 신탁재산을 수탁자들의 합유로 하고 있으므로 위 신탁재산에 관한 소송도 고유필수적 공동소송이 된다.

판례에 의하여 고유필수적 공동소송으로 인정된 사례는 다음과 같다.

① 합유인 조합재산(민법 271조, 704조)에 관한 소송, 예컨대 조합재산으로 매수한 부동산에 관한 소유권이전등기청구의 소(대법원 1994. 10. 25. 선고 93다54064 판결), 조합재산에 속하는 채권에 관한 소송(대법원 1967. 8. 29. 선고 66다2200 판결). 이 유형은 합유자가 적극적 당사자가 되는 경우로서 합유물의 보존행위에 해당하지 않는 경우이다.

② 공동광업권에 관한 소송. 광업권을 공유하는 자들 사이에는 조합계약을 한 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 광업권자가 사망하여 상속인들이 그 광업권을 공동으로 상속하는 경우에도 그 상속인들 사이에 조합계약을 체결한 것으로 보아야 하므로, 그 합유인 공동광업권에 관한 소송은 합일확정을 요하는 필수적 공동소송이다(대법원 1995. 5. 23. 선고 94다23500 판결).

③ 여러 사람의 공동명의로 얻은 허가권이나 면허권(예컨대 주류 공동제조 면허의 경우 공동명 의자의 상호관계는 민법상 조합)에 관한 소송(대법원 1993. 7. 13. 선고 93다12060 판결)

그러나 합유물에 관한 것이라도 예외적으로 합유물에 관하여 경료된 원인 무효의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송과 같이 보존행위에 관한 소송

은 합유자 각자가 할 수 있다(대법원 1997. 9. 9. 선고 96다16896 판결).

조합관계소송이라고 하더라도 ① 조합의 채권자가 조합원에 대하여 조합 재산에 의한 공동책임을 묻는 것이 아니라 각 조합원의 개인적 책임(민법 712조)에 기하여 그 채권을 행사하는 소송(대법원 1991. 11. 22. 선고 91다 30705 판결), ② 조합의 목적 달성으로 인하여 조합이 해산되었으나 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 다만 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요가 없이 각 조합원이 자신의 잔여재산의 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 바로 잔여재산의 분배를 청구하는 소송(대법원 2000. 4. 21. 선고 99다35713 판결)은 고유필수적 공동소송이 아니다.

한편 공동명의의 예금채권자들의 예금반환청구가 필수적 공동소송인지 여부가 문제 되는데, 만일 동업자들이 동업자금을 공동명의로 예금한 경우라면 채권의 준합유관계에 있어 합유의 성질상 공동명의 예금채권자들의 은행에 대한 예금 반환청구가 필수적 공동소송에 해당하지만, 공동명의 예금채권자들 중 1인이 전부를 출연하거나 또는 각자가 분담하여 출연한 돈을 동업 이외의 특정 목적을 위하여 공동명의로 예치해 둬으로써 그 목적이 달성되기 전에는 공동명의 예금채권자가 자신의 예금에 대하여도 혼자서는 인출할 수 없도록 방지, 감시하고자 하는 목적으로 공동명의로 예금을 개설한 경우에는 그 예금에 관한 관리처분권까지 공동명의 예금채권자 모두에게 공동으로 귀속된다고 볼 수 없으므로, 이러한 경우에는 은행에 대한 예금반환청구가 필수적 공동소송에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1994. 4. 26. 선고 93다 31825 판결).

(나) 재산권이 총유인 경우

판례는 법인이 아닌 사단의 재산관계(총유재산관계)에 관한 소송은 사단 자체의 명의로 소송할 수 있는 외에 그 구성원 전원이 당사자로 나서서 소송을 할 수 있으며, 이때의 소송관계는 필수적 공동소송관계라고 한다(대법원

1994. 5. 24. 선고 92다50232 판결, 대법원 1995. 9. 5. 선고 95다21303 판결).
 공유재산의 보존행위로서 소를 제기하는 경우도 법인 아닌 사단이 그 명의로
 사원총회의 결의를 거쳐 하거나 또는 그 구성원 전원이 당사자가 되어
 필수적 공동소송의 형태로 할 수 있을 뿐이다(대법원 2005. 9. 15. 선고 2004
 다44971 전원합의체 판결). 공유물의 관리처분권이 구성원 모두에게 귀속됨을
 전제로 한 것이다(민법 276조).

(다) 재산권의 관리처분권 또는 소송수행권이 합유인 경우

파산관재인(회생채무자 관리인)이 여러 사람인 경우에는 법원의 허가를 얻
 어 직무를 분장하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 관리처분권이 파산관
 재인(회생채무자 관리인) 모두에게 합유적으로 귀속되므로(채무자회생 75조,
 360조), 파산재단(회생채무자 재산)에 관한 소송은 고유필수적 공동소송이 된
 다(대법원 2008. 4. 24. 선고 2006다14363 판결, 대법원 2014. 4. 10. 선고 2013
 다95995 판결).

유언집행자가 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한, 유증 목적물에 대한
 관리처분권은 유언의 본지에 따른 유언의 집행이라는 공동의 임무를 가진
 수인의 유언집행자에게 합유적으로 귀속되므로 유언집행자에게 유증의무의
 이행을 구하는 소송은 유언집행자 전원을 피고로 하는 고유필수적 공동소송
 이다(대법원 2011. 6. 24. 선고 2009다8345 판결).

또한 같은 선정자단에서 여러 선정당사자를 선임하였을 때에는 선정당사
 자 모두가 소송수행권을 합유하는 관계에 있기 때문에 그 소송은 필수적 공
 동소송이 된다.

위와 같이 관리처분권 또는 소송수행권을 합유하는 사람들 중 일부가 그
 자격을 상실한 때에는 남아 있는 사람에게 관리처분권이 귀속된다(민소 54
 조, 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006다14363 판결).

(라) 공유관계와 필수적 공동소송

대체로 판례는 공유관계 소송에 있어서 소유권이 지분의 형식으로 공존할

뿐 지분권 처분의 자유가 있고, 관리처분권이 공동으로 귀속하지 않는다거나 공유물의 보존행위(민법 265조 단서)에 해당한다는 이유로 대부분의 공유관계 소송을 고유필수적 공동소송으로 보지 않는다. 따라서 공유자가 보존행위로서 할 수 있는 공유물의 방해배제청구, 공유물의 인도청구(공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 인도를 청구하는 경우는 보존행위에 해당하지 아니한다. 대법원 2020. 5. 21. 선고 2018다287522 전원합의체 판결), 등기말소청구는 모두 필수적 공동소송이 아니다. 그리고 공동점유물의 인도청구나 공유건물의 철거청구도 공동점유자나 공유자 전원을 공동피고로 하여야 하는 필수적 공동소송이라 할 수 없고, 각자에 대하여 그 지분권의 한도 내에서 인도 또는 철거를 구할 수 있다(대법원 1969. 7. 22. 선고 69다609 판결, 대법원 1993. 2. 23. 선고 92다49218 판결). 그러나 공유물 전체에 대한 소유권 확인은 이를 다투는 제3자를 상대로 공유자 전원이 하여야 하는 것이지 공유자 일부만이 그 관계를 대외적으로 주장할 수는 없다(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다35008 판결).

분할 전 상속재산은 공유관계(민법 1006조)이므로(대법원 1996. 2. 9. 선고 94다61649 판결), 이에 관한 소송은 필수적 공동소송이 아닌 통상공동소송으로 보아야 할 것이다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다29801 판결). 공동상속재산의 지분에 관한 지분권존재확인을 구하는 소송은 고유필수적 공동소송이 아니지만(대법원 2010. 2. 25. 선고 2008다96963 판결), 공동상속인이 다른 공동상속인을 상대로 어떤 재산이 상속재산임의 확인을 구하는 소는 고유필수적 공동소송이다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006다40980 판결).

수인의 채권자가 각기 채권을 담보하기 위하여 채무자와 채무자 소유의 부동산에 관하여 수인의 채권자를 공동매수인으로 하는 1개의 매매예약을 체결하고 그에 따라 수인의 채권자 공동명의로 그 부동산에 가등기를 마친 경우, 수인의 채권자가 공동으로 매매예약완결권을 가지는 관계인지 아니면

채권자 각자의 지분별로 별개의 독립적인 매매예약완결권을 가지는 관계인지는 매매예약의 내용에 따라야 하고, 매매예약에서 그러한 내용을 명시적으로 정하지 않은 경우에는 수인의 채권자가 공동으로 매매예약을 체결하게 된 동기 및 경위, 매매예약에 의하여 달성하려는 담보의 목적, 담보 관련 권리를 공동 행사하려는 의사의 유무, 채권자별 구체적인 지분권의 표시 여부 및 지분권 비율과 피담보채권 비율의 일치 여부, 가등기담보권 설정의 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 2. 16. 선고 2010다82530 전원합의체 판결).

다만 택지개발예정지구 내의 이주자택지 공급대상자가 사망하여 공동상속인들이 이주자택지에 관한 공급계약을 체결할 수 있는 청약권을 공동으로 상속하는 경우에는 공동상속인들이 그 상속지분비율에 따라 피상속인의 청약권을 준공유하게 되며, 공동상속인들은 단독으로 청약권 전부는 물론 그 상속지분에 관하여도 이를 행사할 수 없고, 그 청약권을 준공유하고 있는 공동상속인들 전원이 공동으로만 이를 행사할 수 있는 것이므로 위 청약권에 기하여 청약의 의사표시를 하고, 그에 대한 승낙의 의사표시를 구하는 소송은 청약권의 준공유자 전원이 원고가 되어야 하는 고유필수적 공동소송이다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003다11738 판결).

다. 고유필수적 공동소송인의 추가

법원은 고유필수적 공동소송인 가운데 일부가 누락된 경우에는 제1심의 변론을 종결할 때까지 원고의 신청에 따라 결정으로 원고 또는 피고를 추가하도록 허가할 수 있다(민소 68조 1항 본문). 다만 원고의 추가는 추가될 사람의 동의를 받은 경우에만 허가할 수 있다(단서). 고유필수적 공동소송인의 추가신청은 원고에게만 신청권이 있으므로 피고나 제3자에게는 신청권이 없다.

고유필수적 공동소송인의 추가신청은 추가될 당사자의 이름·주소와 추가신청의 이유를 적은 서면으로 하여야 한다(민소규 14조). 추가신청을 서면으

로 하도록 한 것은 추가신청이 추가된 당사자와의 사이에서는 새로운 소의 제기와 같은 실질을 가지고 있는 점과 피고의 경정신청을 서면으로 하도록 하고 있는 민사소송법 260조 2항과의 균형 등을 고려한 것이다. 다만 소액 사건에서는 구술로도 필수적 공동소송인 추가신청을 할 수 있다고 해석되므로(소액 2조 2항, 4조 1항), 그 경우에는 위 기재사항을 말로 진술하여야 하고, 법원사무관등은 제소조서에 준하는 조서를 작성하여야 할 것이다. 추가신청서에는 인지를 붙이지 아니하고, 문건으로 전산입력하며, 가철한다(인지액·편철방법예규).

원고의 추가신청에 대하여 법원은 결정으로 그 허부를 재판한다(민소 68조 1항). 법원이 필수적 공동소송인의 추가를 허가하는 결정을 한 때에는 허가 결정의 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하며, 추가될 당사자에게는 소장부분도 송달하여야 한다(2항).

허가결정에 대하여는 원칙적으로 불복할 수 없으나, 추가될 원고의 동의가 없었다는 것을 사유로 하는 경우에만 이해관계인의 즉시항고가 허용되며(민소 68조 4항), 그 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 아니한다(5항). 피고 경정신청의 기각결정에 대하여는 통상항고(439조)만 허용되지만, 공동소송인의 추가신청을 기각한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(68조 6항).

필수적 공동소송이 아닌 사건에서는 소송 도중에 당사자를 추가하는 것이 허용될 수 없었는데(대법원 1993. 9. 28. 선고 93다32095 판결), 2002년 민사소송법의 개정으로 필수적 공동소송인의 추가에 관한 규정이 예비적·선택적 공동소송의 경우에도 준용됨으로써(민소 70조 1항, 68조) 예외적으로 당사자의 추가가 가능하게 되었다.

다만 판례 중에는 고유필수적 공동소송인이나 예비적·선택적 공동소송인의 관계에 있지 않은 당사자를 추가하는 신청을 하였는데 그 부적법한 신청이 제1심법원에서 받아들여지고 판결이 선고된 사안에서, 추가된 당사자에 대하여 충분한 변론기회가 부여되었으며 소송절차상의 혼란이 초래되었다고

볼 수 없다는 등의 여러 사정을 종합하여 소송경제의 측면이나 신의칙의 관점에서 당사자추가신청의 적법 여부를 더 이상 다룰 수 없다고 한 경우가 있다(대법원 1998. 1. 23. 선고 96다41496 판결, 대법원 2015. 8. 13. 선고 2014다67522 판결).

법원의 허가결정에 의하여 공동소송인의 추가가 있는 때에는 처음 소가 제기된 때에 추가된 당사자와의 사이에 소가 제기된 것으로 본다(민소 68조 3항). 필수적 공동소송인의 추가이므로 종전의 공동소송인이 행한 소송수행의 결과는 유리한 소송행위의 범위 내에서 추가된 당사자에게도 효력이 미친다.

3. 유사필수적 공동소송

‘유사필수적 공동소송’이란 공동소송인들이 반드시 공동으로 소송을 수행할 필요는 없으나 일단 공동소송으로 된 이상 합일확정이 요청되어 승패를 일률적으로 하여야 할 공동소송형태를 말한다. 공동소송인 가운데 한 사람과 상대방 사이의 판결이 당연히 다른 공동소송인에게도 그 효력이 미치는 관계에 있기 때문에 공동하여 소송하는 이상 각각의 사람에 대하여 별개의 판결을 할 수 없는 경우의 공동소송이다.

유사필수적 공동소송의 유형으로는 판결의 본래적 효력(기판력·집행력·형성력)이 직접 제3자에게 확장되어 유사필수적 공동소송이 성립하는 경우(상법 184조, 190조 본문, 236조, 376조, 380조, 381조, 채무자회생 176조, 468조)와 합일확정의 필요에 따라 개별법에서 특별 규정을 두고 있는 경우(민집 249조, 상법 403조)가 있다(대법원은 주주총회결의의 부존재 또는 무효 확인을 구하는 소의 청구를 인용하는 판결은 상법 380조에 의해 준용되는 상법 190조 본문에 따라 제3자에 대하여도 효력이 있다고 판시하였다. 대법원 2021. 7. 22. 선고 2020다284977 전원합의체 판결). 더 나아가 판례는 각 채권자대위권에 기하여 공동하여 채무자의 권리를 행사하는 다수의 채권자들은 채무자가 채권자

대위권에 의한 소송이 제기된 것을 알았을 경우에는 유사필수적 공동소송관계에 있다고 판시하였다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91다23486 판결).

주의할 점은 공동소송인 간에 있어서 합일확정이 단순히 논리상 또는 실무상 요청되는 경우(이러한 경우를 종래 ‘이론상 합일확정소송’이라고 하였다)까지 필수적 공동소송에 포함되는 것은 아니라는 점이다. 예컨대 보증채무의 주채무에 대한 관계와 같이 타인의 의무에 부종하는 경우 또는 연대채무와 같이 동일한 사실관계가 모든 공동소송인의 권리나 의무의 기초가 되는 경우 등은 필수적 공동소송이 아니다.

4. 필수적 공동소송의 심판

가. 총 설

필수적 공동소송은 합일확정을 요하는 공동소송이기 때문에 합일확정이 필요한 본안심리의 소송수행상 소송자료의 통일과 소송진행의 통일이 요청된다.

나. 소송요건의 조사

소송요건은 공동소송인 각자에 대하여 조사하되, 고유필수적 공동소송의 경우에는 1인에 대한 소송요건이라도 흠이 있으면 전원의 소를 각하하고, 유사필수적 공동소송의 경우에는 그 흠이 있는 당사자의 부분만 분리하여 각하한다.

고유필수적 공동소송인이 되어야 할 일부 당사자가 누락되었을 경우에는 앞서 본 바와 같이 필수적 공동소송인의 추가가 가능하다(민소 68조). 별소제기와 변론병합(141조) 또는 공동소송참가(83조) 등의 방법으로도 누락된 사람을 보정할 수 있다.

다. 소송자료의 통일

공동소송인 가운데 한 사람이 한 유리한 소송행위는 모두를 위하여 효력이 생기지만, 불리한 소송행위는 모두 함께 하지 아니하면 효력이 생기지 아니한다(민소 67조 1항). 따라서 한 사람의 부인, 항변, 증거제출은 이익이 되는 소송행위이기 때문에 모두에게 효력이 있으나, 자백, 청구의 포기·인낙, 화해, 소취하 등은 불리한 소송행위이므로 모두 함께 하지 아니하면 효력이 없다. 다만 유사필수적 공동소송에 있어서는 한 사람의 소취하도 가능하다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2011두16087 판결).

공동소송인의 모순된 행위는 그 본래의 효과는 발생하지 않으나, 그 모순된 행위는 변론의 내용이 되어 변론 전체의 취지로 공동소송인 측에 불리하게 참작될 수 있다. 공동소송인의 1인이 기일에 출석하여 변론하거나 또는 기간을 준수하였다면 다른 공동소송인이 결석하거나 기간을 준수하지 못하였어도 공동소송인에게 불리한 효과가 발생하지 않는다. 다만 유사필수적 공동소송의 경우에는 공동소송인의 1인에 대한 이른바 쌍불취하간주가 적용된다(반대설 있음).

상대방의 소송행위는 공동소송인의 1인에 대하여 하더라도 모두에게 효력이 있다(민소 67조 2항).

라. 소송진행의 통일

변론 및 증거조사는 공통된 기일에 한다. 변론의 분리나 공동소송인 일부에 대한 판결은 모순된 판결을 피하기 위하여 허용되지 않는다. 상소기간이 모두에게 경과하기까지 판결이 확정되지 아니한다.

필수적 공동소송에서는 공동소송인 중 일부가 제기한 상소 또는 공동소송인 중 일부에 대한 상대방의 상소는 다른 공동소송인에게도 효력이 미치는 것이므로 공동소송인 전원에 대한 관계에서 판결의 확정이 차단되고 소송은 전체로서 상소심에 이심되며, 상소심판결의 효력은 상소를 하지 아니한 공

동소송인에게 미치므로 상소심으로서의 공동소송인 전원에 대하여 심리·판단하여야 한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91다23486 판결). 이러한 필수적 공동소송에 대하여 본안판결을 할 때에는 공동소송인 전원에 대한 하나의 중국판결을 선고하여야 하는 것이지 공동소송인 일부에 대해서만 판결하거나 남은 공동소송인에 대해 추가판결을 하는 것은 모두 허용될 수 없다(대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결).

이 경우 상소를 제기하지 아니한 다른 공동소송인은 그 지위를 상소인이라기보다 합일확정의 요청 때문에 그 소송관계가 상소심으로 이심하게 되는 단순한 ‘상소심 당사자’로 파악하여야 할 것이다. 대법원은 필수적 공동소송에서 당사자표시 중 상고하지 않은 피고를 ‘피고, 상고인’으로 표시하지 않고 단순히 ‘피고’라고만 표시하거나(대법원 1995. 1. 12. 선고 94다33002 판결) ‘피고, 상고심 당사자’라고 표시하고, 상고비용을 상고한 피고에게만 부담시키고 있다.

1인에 대하여 중단·중지의 원인이 있으면 소송 전부가 정지된다(민소 67조 3항).

제4절 예비적·선택적 공동소송

1. 의 의

‘예비적·선택적 공동소송’이란 공동소송인 가운데 일부의 청구가 다른 공동소송인의 청구와 법률상 양립할 수 없거나(공동원고의 청구), 공동소송인 가운데 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 양립할 수 없는 경우(공동피고에 대한 청구)의 공동소송을 말한다(민소 70조 1항).

법원의 판단에 관하여 심판의 순서를 정하여 청구하는 것이 예비적 공동소송이고, 순서를 정하지 아니하고 법원의 선택에 맡긴 것이 선택적 공동소

송이다.

소의 객관적 병합에서 ‘주위적·예비적 관계’란 1차적으로 주위적인 것을 인용해 줄 것을 해제조건으로 하여, 이러한 주위적인 것이 이유가 없어 받아들여지지 않으면 2차적으로 예비적인 것을 받아들여질 것을 바라는 관계를 말하고, ‘선택적 관계’란 여러 가지의 청구 중 하나를 법원이 선택하여 인용해 줄 것을 바라는 관계를 말한다. 따라서 주위적·예비적 관계에서 주위적인 것이 받아들여지면 예비적인 것에 대해서는 판단하지 않아도 되고, 선택적 관계에서 어느 하나가 받아들여지면 선택되지 않은 나머지 것에 대해서는 판단하지 않아도 된다.

그러나 예비적·선택적 공동소송에서는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하여야 하므로(민소 70조 2항), 예비적 공동소송에서 예비적이라는 의미는 위와 같은 해제조건부란 의미에서의 예비적이란 말의 의미와 달리 소송계속은 모든 공동소송인에게 무조건 생기되, 다만 청구인용판결을 해제조건부로 구한다는 의미이고, 선택적 공동소송에서 선택적이란 의미도 소송계속은 모든 공동소송인에게 무조건 생기되, 다만 그중 하나의 청구만을 받아들여 달라는 의미이다.

2. 요건

가. 공동소송의 일반 요건

예비적·선택적 공동소송은 공동소송의 특수한 형태이므로, 공동소송의 일반 요건을 갖추어야 한다(민소 65조, 253조).

나. 후발적 발생

법률상 양립할 수 없는 청구를 소제기 시부터 심판의 순서를 정하거나 선택적으로 하여 구하는 것이 예비적·선택적 공동소송의 일반적인 경우일 것이나, 제1심의 변론을 종결할 때까지 당사자를 추가하는 방식에 의하여도

예비적·선택적 공동소송이 될 수 있다(민소 70조 1항, 68조 1항). 그리고 예비적·선택적 공동소송인을 추가하는 허가결정을 한 때에는 그 허가결정의 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하고, 추가될 당사자에게는 소장부본도 송달하여야 하며(68조 2항), 추가된 당사자에 대한 관계에서는 처음의 소가 제기된 때에 소가 제기된 것으로 간주된다(3항). 따라서 원고가 어느 한 사람을 피고로 지정하여 소를 제기하였다가 다른 사람이 주위적 또는 예비적 피고의 지위에 있다고 주장하면서 그에 대한 청구를 아울러 하는 경우, 법원은 그것이 주위적 또는 예비적 피고를 추가하는 취지인지 여부를 밝혀 그에 따른 조치를 취하여야 한다(대법원 2008. 4. 10. 선고 2007다86860 판결).

그러나 처음에는 공동소송인을 상대로 각자 개별적으로 법률상 양립할 수 없는 소송을 제기하거나, 공동소송인 각자가 개별적으로 법률상 양립할 수 없는 청구를 하였다가 변론의 병합으로 인하여 공동소송이 된 후 청구의 변경 등으로 공동소송인 가운데 심판의 순서를 지정하거나 선택적으로 심판하여 달라고 청구하는 형태의 예비적·선택적 공동소송이 가능한지에 대하여 견해가 대립된다. 이미 발생한 자백의 효력 등 소송법상의 효력을 병합으로 인하여 반복할 수 없는 상태에 있거나, 변론의 병합을 허용하면 소송절차가 복잡해지는 등의 염려가 없는 한 이를 긍정하여도 좋을 것이다(반대설 있음).

한편 그 종기에 관하여는 당사자의 변론 기회의 확보와 심급의 이익을 지키기 위한 요건이므로, 항소심에서도 상대방이 동의를 한다면 예비적·선택적 공동소송이 가능하다는 견해도 있으나, 법문에 반하므로 제1심의 변론을 종결할 때까지만 가능하다고 보아야 할 것이다.

다. 청구의 법률상 양립 불가능

예비적·선택적 공동소송인의 청구 또는 이들에 대한 청구가 법률상 양립할 수 없어야 한다(민소 70조 1항). ‘법률상 양립할 수 없다’는 것은 공동소송인 가운데 일부가 권리자나 의무자이면 나머지 공동소송인은 권리자나 의무

자가 될 수 없음을 뜻한다.

법률상 양립할 수 없는 경우에 해당하는 전형적인 사례로는 ① 갑의 대리인 을을 통해 계약을 했으나 을에게 대리권이 있는지 여부가 분명하지 않아 갑에 대하여는 계약상의 청구를, 을에 대하여는 무권대리인에 대한 손해배상청구를 하는 경우, ② 갑이 을에게 채무자 병에 대한 채권을 양도하였으나 채권양도의 효력발생이 분명하지 않아 갑은 병을 상대로 본래의 청구를 하고, 을은 병을 상대로 양수금 청구를 하는 경우, ③ 공작물의 설치·보존에 하자가 있음을 이유로 점유자를 주위적 피고로, 그것이 인용되지 아니할 경우를 대비하여 소유자를 예비적 피고로 하여 청구하는 경우(민법 758조)를 들 수 있다.

사실상 원인에 의하여 양립할 수 없는 경우도 예비적·선택적 공동소송을 할 수 있는지에 관하여는 견해의 대립이 있으나 판례(대법원 2007. 6. 26. 자 2007마515 결정)는 “민사소송법 70조 1항에 있어서 ‘법률상 양립할 수 없다’는 것은 동일한 사실관계에 대한 법률적인 평가를 달리하여 두 청구 중 어느 한쪽에 대한 법률효과가 인정되면 다른 쪽에 대한 법률효과가 부정됨으로써 두 청구가 모두 인용될 수는 없는 관계에 있는 경우나, 당사자들 사이의 사실관계 여하에 의하여 또는 청구원인을 구성하는 택일적 사실인정에 의하여 어느 일방의 법률효과를 긍정하거나 부정하고 이로써 다른 일방의 법률효과를 부정하거나 긍정하는 반대의 결과가 되는 경우로서, 두 청구들 사이에서 한쪽 청구에 대한 판단 이유가 다른 쪽 청구에 대한 판단 이유에 영향을 주어 각 청구에 대한 판단 과정이 필연적으로 상호 결합되어 있는 관계를 의미한다.”라고 하여 긍정설을 취하였다. 위 판례는 나아가 “실체법적으로 서로 양립할 수 없는 경우뿐 아니라 소송법상으로 서로 양립할 수 없는 경우를 포함한다.”라고 하여 어느 한쪽에 대한 청구는 부적법하고 다른 쪽에 대한 청구만이 적법한 경우도 가능하다고 판단하였다. 따라서 아파트 입주자대표회의의 구성원 개인을 피고로 삼아 제기한 동대표지위 부존재확인

의 소의 계속 중에 아파트 입주자대표회의를 피고로 추가하는 것은 누가 피고적격을 가지는지에 관한 법률적 평가에 따라 어느 한쪽에 대한 청구는 부적법하고 다른 쪽의 청구만이 적법하게 될 수 있으므로, 이러한 주관적·예비적 추가는 허용된다.

한편 민사소송법 70조 1항 본문이 규정한 '공동소송인 가운데 일부에 대한 청구'를 반드시 '공동소송인 가운데 일부에 대한 모든 청구'라고 해석할 근거는 없으므로, 주위적 피고에 대한 주위적·예비적 청구 중 주위적 청구 부분이 인용되지 아니할 경우 그와 법률상 양립할 수 없는 관계에 있는 예비적 피고에 대한 청구를 인용하여 달라는 취지로 결합하여 소를 제기하는 것도 가능하다(대법원 2009. 3. 26. 선고 2006다47677 판결).

부진정연대채무 관계는 서로 별개의 원인으로 발생한 독립된 채무라 하더라도 동일한 경제적 목적을 가지고 있고 서로 중첩되는 부분에 관하여 일방의 채무가 변제 등으로 소멸할 경우 타방의 채무도 소멸하는 관계에 있으면 성립할 수 있고, 반드시 양 채무의 발생원인, 채무의 액수 등이 서로 동일할 것을 요한다고 할 수는 없으며, 부진정연대채무의 관계에 있는 채무자들을 공동피고로 하여 이행의 소가 제기된 경우 그 공동피고에 대한 각 청구가 서로 법률상 양립할 수 없는 것이 아니므로 그 소송을 민사소송법 70조 1항 소정의 예비적·선택적 공동소송이라고 할 수 없다(위 대법원 2006다47677 판결, 대법원 2012. 9. 27. 선고 2011다76747 판결).

3. 심 판

가. 소송자료의 통일

민사소송법 70조 1항은 예비적·선택적 공동소송에 있어서 필수적 공동소송에 관한 67조의 특칙을 원칙적으로 준용하도록 규정하고 있다. 그러나 자백 등 소송자료의 통일 여부에 관하여는 위 법 규정의 입법 취지에 관한 해석 및 예비적·선택적 공동소송의 성질과 관련하여, 필수적 공동소송에 관한

67조의 특칙을 전면적으로 준용하여야 한다는 ‘전면적 준용설’과 이를 제한적으로 준용하면 충분하다는 ‘제한적 준용설’로 해석이 나뉘고 있다.

전면적 준용설은 소송자료의 경우에 민사소송법 70조 1항 단서의 예외를 제외하고는 67조가 준용되어 공동소송인 가운데 한 사람의 소송행위는 전원의 이익을 위하여만 효력이 발생하고, 공동소송인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 행위는 유리·불리를 묻지 않고 공동소송인 모두에게 효력이 있다는 견해이다.

제한적 준용설은 예비적·선택적 공동소송의 도입목적은 분쟁의 모순 없는 일회적 해결과 이를 위한 분리확정방지에 있고 이는 절차진행의 통일성 확보로 충분하며, 소송자료의 통일은 제한된 범위 안에서만 허용하면 충분하다는 견해이다.

위와 같은 견해의 대립을 참조하여 공동소송인의 소송행위 중 문제가 되는 경우를 나누어 살펴본다.

(1) 재판상 자백

전면적 준용설에 따르면 필수적 공동소송이나 독립당사자참가의 경우에 민사소송법 67조의 규정을 적용하는 것과 마찬가지로 취급하게 된다. 따라서 공동소송인 가운데 한 사람의 소송행위는 전원의 이익을 위하여만 효력이 발생하므로, 주위적·예비적 피고 또는 선택적 피고 중 한 사람이 자백하여도 효력이 없다.

제한적 준용설에 따르면 주위적·예비적 피고 또는 선택적 피고 중 한 사람이 자백을 한 경우, 이는 부인하고 있는 다른 공동소송인의 이익을 해치는 것이 아니므로 그대로 자백의 효력을 인정할 수 있다. 물론 공동소송인 모두가 서로 양립할 수 없는 청구의 개개의 주요사실에 대하여 함께 하는 자백의 효력도 인정된다. 예컨대 선택적 공동소송에서 선택적 피고 모두가 자백한 경우 법원은 선택적 피고 중 누구에 대하여도 자백의 효력을 인정하여 승소판결을 할 수 있다.

한편 예비적 공동소송의 경우에 ① 주위적 피고만 자백한 경우에는 주위적 피고에 대한 원고의 청구를 인용하고, 그 인용을 이유로 예비적 피고에 대한 청구를 기각하고, ② 예비적 피고만 자백한 경우에는 주위적 피고에 대한 청구를 판단하는 때에는 예비적 피고의 자백을 고려할 필요 없이 소송자료에 기초하여 당부를 판단하여 주위적 피고에 대한 청구가 인용되면 예비적 피고에 대한 청구를 기각하며, 주위적 피고에 대한 청구가 기각되면 예비적 피고에 대한 청구를 판단하여 예비적 피고의 자백에 따라 청구를 인용하고, ③ 주위적·예비적 피고가 모두 자백한 경우에는 주위적 피고에 대한 원고의 청구를 인용하고, 그 인용을 이유로 예비적 피고에 대한 청구를 기각하며, 예비적 피고의 자백은 고려할 필요가 없다는 견해도 있다.

(2) 기일 불출석 또는 기간 부준수의 불이익

전면적 준용설에 따르면, 예비적·선택적 공동소송인 중 일부의 공동소송인이 변론기일 또는 변론준비기일에 나가 변론·진술을 하였다면 그 기일에 불출석한 공동소송인은 기일 불출석의 불이익을 받지 않으며, 공동소송인 가운데 한 사람이 기간을 지켰으면 다른 사람이 지키지 못하여도 기간 준수를 게을리한 불이익을 입지 않는다고 보게 된다.

제한적 준용설에 따르면, 당해 기일에 불출석한 공동소송인은 다른 공동소송인의 이익을 해치는 것이 아니므로, 기일 불출석 등의 불이익을 입는다고 해석하게 된다.

(3) 청구의 포기·인낙, 화해 및 소의 취하

민사소송법 70조 1항 단서는 예비적·선택적 공동소송에 있어서 같은 법 67조를 준용하는 예외로서, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해 또는 소취하를 규정하고 있다. 따라서 공동원고의 한 사람이 청구를 포기하거나 소를 취하하면 나머지 공동원고와 피고 사이에서, 공동피고 중 한 사람에 대한 청구를 포기하거나 소를 취하하면 원고와 나머지 공동피고 사이에서 각 소송이 진행될 것이다(소를 취하지 않은 나머지 공동소송인에 관한 청구 부분은 여전히

심판의 대상이 된다는 판시는 대법원 2018. 2. 13. 선고 2015다242429 판결).

그러므로 예비적·선택적 공동소송에서 조정을 갈음하는 결정에 대하여 일부 공동소송인이 이의하지 않았다면 원칙적으로 그 공동소송인에 대한 판례에서는 조정을 갈음하는 결정이 확정될 수 있다. 그러나 조정을 갈음하는 결정에서 분리 확정을 불허하고 있거나, 그렇지 않더라도 그 결정에서 정한 사항이 공동소송인들에게 공통되는 법률관계를 형성함을 전제로 하여 이해관계를 조절하는 경우 등과 같이 결정 사항의 취지에 비추어 볼 때에 분리확정을 허용할 경우 형평에 반하고 또한 이해관계가 상반된 공동소송인들 사이에서의 소송진행 통일을 목적으로 하는 민사소송법 70조 1항 본문의 입법 취지에 반하는 결과가 초래되는 경우에는 분리확정이 허용되지 않는다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006다57872 판결, 화해권고결정에 관하여 같은 판시는 대법원 2015. 3. 20. 선고 2014다75202 판결). 이 경우 화해권고결정에 대하여 일부 공동소송인만이 이의신청을 한 후 그 공동소송인 전원이 분리확정에 대하여는 이의가 없다는 취지로 진술하였더라도 분리확정이 허용되지 않는다(대법원 2022. 4. 14. 선고 2020다224975 판결).

한편 예비적 공동소송에 있어서 청구의 인낙에 관하여는 견해가 나누어진 다. 편의상 피고 측 공동소송의 경우를 상정하여 설명하면 다음과 같다.

먼저 주위적 피고는 청구를 인낙하지 않고 있는데 예비적 피고가 청구를 인낙하는 것이 허용될 것인가의 문제이다. 이에 대하여는 주위적·예비적 피고 누구든지 인낙이 가능하다는 견해가 있는 반면, 주위적 피고의 인낙만이 효력이 있을 뿐이고, 예비적 피고의 인낙은 효력이 없다는 견해도 있다.

다음으로 주위적 피고가 인낙한 후 남게 되는 예비적 피고와의 소송 관계가 문제 된다. 이에 대하여는 주위적 피고의 인낙으로 청구에 관하여 원하는 결과를 얻었으므로 인낙하지 않은 예비적 피고에 대한 청구는 받아들일 수 없다는 견해가 있다. 반면 민사소송법 70조 1항 단서에서 인낙의 경우 67조의 적용을 배제한다고 규정한 취지는 인낙 이후의 소송은 단일소송으로 환

원되어 통상공동소송과 같은 절차진행을 하여야 한다는 의미이므로 예비적 피고와의 소송을 계속 진행하여야 한다는 견해가 있다. 후자의 견해에 따르면 주위적 피고가 인낙한 후 남게 되는 예비적 피고와의 소송에서 원고가 승소할 수도 있게 된다.

(4) 상 계

예비적·선택적 공동소송에서 공동피고 중 한 사람이 상계항변을 하는 경우, 그 상계항변은 나머지 공동피고와는 아무런 유리·불리의 관계가 없으므로 상계항변을 한 공동피고에 대한 청구가 인용될 경우에 그 상계항변을 판단하면 된다.

나. 소송진행의 통일

예비적·선택적 공동소송의 소송진행은 통일적이어야 한다. 소송진행이 통일적으로 이루어져야 하는 경우를 몇 가지로 나누어 본다.

(1) 변론 및 증거조사

변론 및 증거조사는 공통된 기일에 실시한다. 이른바 후발적 예비적·선택적 공동소송의 경우 당사자가 병합신청을 철회함으로써 별소로서도 심리를 받을 수 있는지에 관하여 학설상 대립이 있으나, 분쟁의 모순 없는 일회적 해결이라는 점에서 당사자의 병합신청 철회 여부를 묻지 않고 변론의 분리를 허용하여서는 안 될 것이다.

(2) 소송절차의 중단·중지

예비적·선택적 공동소송인 중 한 사람에 대하여 소송절차의 중단·중지의 원인이 발생하면 다른 사람에게도 영향을 미쳐 전체 소송절차의 진행이 정지된다(민소 70조 1항, 67조 3항).

(3) 판 결

판결의 내용이 공동소송인 사이에 서로 어긋나는 것을 회피하기 위하여 예비적·선택적 공동소송인 모두에 대하여 하나의 전부판결로 법률상 양립

할 수 없는 법률관계를 가려야 하고(민소 70조 2항), 일부 공동소송인에 대하여만 판결을 하거나 남겨진 공동소송인을 위하여 추가판결을 하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2008. 4. 10. 선고 2007다36308 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2009다43355 판결).

예비적·선택적 공동소송의 경우 반드시 어느 한 청구를 인용하여야 하는 것은 아니지만, 예비적 공동소송의 경우 주위적 청구를 받아들이면 예비적 공동소송인에 대하여 청구를 기각하는 판결을 하여야 하고, 선택적 공동소송의 경우 어느 청구를 받아들여 인용판결을 하면 나머지 공동소송인에 대하여 청구를 기각하는 판결을 하여야 한다.

착오로 일부판결을 하더라도 추가판결을 하여 사건을 둘로 나눌 수 없기 때문에 전부판결을 한 것으로 취급하여 상소로써 다투어야 한다. 따라서 판결문의 당사자에서 누락된 예비적·선택적 공동소송인도 착오로 인한 일부판결을 시정하기 위하여 상소를 제기할 이익이 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다49430 판결).

(4) 상 소

피고 측 예비적 공동소송에서 원고가 주위적 피고에 대하여 승소한 경우나, 피고 측 선택적 공동소송의 경우 어느 한 피고에 대하여 승소한 경우에는 패소한 피고에게만 상소의 이익이 있고 원고 및 승소한 피고에게는 상소의 이익이 없으나, 이 경우 패소한 피고가 상소하면 승소한 피고에 대한 판결도 확정되지 않고 상소심으로 이심된다. 예컨대 원고의 주위적 피고(갑)에 대한 청구가 인용되고 예비적 피고(을)에 대한 청구가 기각된 경우, 갑이 상소하면 을에 대한 판결도 확정되지 않고 상소심으로 이심되는 것이다.

한편 주위적 피고에 대한 청구는 기각되고 예비적 피고에 대한 청구가 인용된 경우에는, 승소한 주위적 피고는 상소의 이익이 없지만 예비적 피고와 원고에게는 상소의 이익이 있다. 이 경우에 원고와 예비적 피고 중 한 사람이 상소하더라도 승소한 피고(주위적 피고)에 대한 판결이 확정되지 않고

상소심으로 이심되어 심판대상이 된다. 이러한 경우 상소심의 심판대상은 주위적·예비적 공동소송인들 및 그 상대방 당사자 사이의 결론의 합일확정의 필요성을 고려하여 그 심판의 범위를 판단하여야 한다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2009다43355 판결, 대법원 2021. 7. 8. 선고 2020다292756 판결).

제1심에서 주위적 피고에 대한 청구는 기각되고 예비적 피고에 대한 청구가 인용되었는데 원고는 항소하지 않고 예비적 피고만이 항소한 경우 항소심에서 심리 결과 예비적 피고의 항소가 이유 있고 주위적 피고에 대한 청구가 정당하다면, 항소심은 제1심판결을 취소하여 주위적 피고에 대한 청구를 인용하고 예비적 피고에 대한 청구를 기각하게 된다. 결국, 이 경우 주위적 피고에 대하여는 불이익변경금지의 원칙이 적용되지 않는다.

이와 같이 항소하지도 않고 항소를 제기당하지도 않은 당사자(위의 경우 주위적 피고)의 지위에 관하여 학설상 대립이 있지만 독립당사자참가의 경우와 마찬가지로 취급하여 항소인 또는 피항소인이 아니라 ‘항소심 당사자’로 보아야 할 것이다. 한편 이러한 당사자, 즉 위의 예에서 본 항소하지 않은 주위적 피고가 원고를 위하여 보조참가할 수 있는지 여부에 관하여 이를 긍정하는 견해도 있지만 주위적 피고 역시 소송당사자이므로 부정하여야 할 것이다.

제11장

소송참가와 소송승계

제1절 총 설 418

제2절 보조참가 418

제3절 공동소송적 보조참가 428

제4절 독립당사자참가 431

제5절 승계참가와 승계인수 439

제6절 공동소송참가 450

제7절 소송고지 453

제1절 총 설

‘소송참가’란 타인 간에 계속 중인 소송에 제3자가 당사자로서 또는 당사자에 준하는 지위에서 관여하는 것을 말한다. 이미 개시된 소송에서 제3자가 자기의 법률상 이익을 지키는 한편, 제3자와의 관련청구도 함께 일거에 해결하여 제3자나 당사자의 이익과 편의에 이바지할 수 있게 하기 위하여 마련된 제도가 소송참가이다. 소송참가에는 보조참가(민소 71조), 공동소송적 보조참가(78조), 독립당사자참가(79조), 공동소송참가(83조) 등이 있다.

‘소송승계’란 소송계속 중에 당사자의 사망이나 소송목적물의 양도 등으로 소송물인 권리 또는 법률관계의 변동이 생긴 결과 당사자적격이 제3자에게 이전되는 경우 그 제3자가 새 당사자로서 전 당사자의 소송상 지위를 승계하는 것을 말한다. 소송승계에는 종전 당사자의 사망 등으로 그 지위가 포괄적으로 제3자에게 승계되는 ‘당연승계’와 양도된 특정 소송물에 관하여 당사자의 신청에 의하여 승계되는 ‘소송물 양도에 따른 승계’가 있다. 소송물 양도에 따른 승계에는 승계참가(민소 81조)와 승계인수(82조)가 있다.

제2절 보조참가

1. 의 의

‘보조참가’란 타인 간의 계속 중인 소송의 결과에 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자를 돕기 위하여 그 소송에 참가하는 것을 말한다. 보조참가는 소가 아니며 보조참가인은 피참가인인 당사자의 승소를 위한 보조자일 뿐 당사자가 아니다. 따라서 국가가 보조참가를 한 경우에는 국가를 당사자로 하는 소송이 아니어서 ‘인지 첩부 및 공탁 제공에 관한 특별법(현 인지 첩부·첩부 및

공탁 제공에 관한 특례법’ 2조가 적용되지 아니하므로 보조참가인의 자격에서 제1심판결에 불복하여 항소를 제기한 경우에는 인지를 붙여야 한다(대법원 1969. 10. 18. 자 69마683 결정, 대법원 2008. 7. 11. 자 2008마600 결정).

2. 요 건

가. 타인 간의 소송이 계속 중일 것

자기가 당사자로 된 소송의 상대방을 위해서는 참가할 수 없으나 자기의 공동소송인이나 그 공동소송인의 상대방을 위해서는 참가할 수 있다. 또 상고심에서도 참가를 할 수 있다. 판결 확정 후 재심사유가 있을 때에는 보조참가인이 피참가인을 보조하기 위하여 보조참가신청과 함께 재심의 소를 제기할 수 있으나 보조참가인의 재심청구 당시 피참가인인 재심청구인이 이미 사망하여 당사자능력이 없다면, 이를 허용하는 규정 등이 없는 한 보조참가인의 재심청구는 허용되지 않는다(대법원 2018. 11. 29. 선고 2018므14210 판결).

그러나 대립하는 당사자구조를 갖지 못한 매각허가결정 절차 등에서는 보조참가를 할 수 없다(대법원 1994. 1. 20. 자 93마1701 결정). 다만 보전처분 또는 그 이의사건의 심문절차 등에서는 실무상 보조참가를 허용하고 있다.

보조참가인이 당사자인 피참가인 또는 상대방의 지위를 승계하거나 또는 소송인수(민소 81조, 82조)를 하여 당사자로 된 때에는 보조참가관계는 소멸된다. 법정대리인은 소송수행상 당사자에 준하여 취급되기 때문에 보조참가인으로 될 수 없다. 다른 사람을 위하여 자기의 이름으로 소송수행하는 경우(제3자의 소송담당), 그 다른 사람인 권리주체는 그 소송에 보조참가할 수 있다(이때는 공동소송적 보조참가가 된다).

보조참가의 효력은 소송이 종료되기까지 유지되므로 상소, 환송, 이송 등의 사유로 심급이 바뀌어도 다시 참가를 할 필요는 없다.

나. 소송결과에 대하여 이해관계가 있을 것

이해관계라 함은 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 당해 소송의 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우(이때는 공동소송적 보조참가가 된다) 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상의 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미하는데(대법원 2007. 4. 26. 선고 2005다19156 판결), 법률상 지위가 결정되는 관계는 참가인의 법률상 지위가 본소에서 확정될 법률효과와 논리적으로 의존관계에 있는 경우로서, 보조참가인의 법률상 지위가 피참가인이 패소판결을 받으면 법률상 불리해지고 승소판결을 받으면 법률상 유리해지는 경우를 말한다. 구체적으로는 피참가인이 패소할 경우 참가인이 구상당하거나 손해배상을 청구당할 가능성이 있는 때가 이러한 경우에 해당한다. 예컨대 채권자가 연대보증인을 상대로 보증채무이행청구소송을 제기한 경우 주채무자는 연대보증인이 소송에서 패소하면 구상금청구소송을 당하게 될 처지에 있기 때문에 이러한 경우 주채무자는 연대보증인의 보조참가인이 될 수 있다.

소송결과에 의하여 영향을 받을 제3자의 법률상 지위는 재산법상의 지위이든 신분법상의 지위이든 상관없으며 또 사법상의 지위뿐만 아니라 공법상의 지위라도 관계없다. 그러나 법률상 이해관계 아닌 사실상·경제상 또는 감정상 이해관계만으로는 참가할 수 없다(대법원 2000. 9. 8. 선고 99다26924 판결). 따라서 동일사고의 공동피해자 가운데 한 사람이 제기한 손해배상청구소송에서 다른 피해자가 원고가 패소하면 자기도 동일한 이유로 패소할 수 있다는 이유로 보조참가를 할 수는 없다. 반면에 불법행위로 인한 손해배상책임을 지는 자는 피해자가 다른 공동불법행위자들을 상대로 제기한 손해배상청구소송의 결과에 대하여 법률상의 이해관계를 가지므로 위 소송에 보조참가를 할 수 있다(대법원 1999. 7. 9. 선고 99다12796 판결).

다른 법률상 구제수단이 있더라도 보조참가를 하는 데 장애가 되지는 않는다. 따라서 독립당사자참가나 공동소송참가를 할 수 있는 경우라도 보조

참가를 할 수 있다. 그러나 보조참가를 하다가 독립당사자참가를 하면 보조참가가 종료된다(대법원 1993. 4. 27. 선고 93다5727, 5734 판결).

다. 소송절차를 현저하게 지연시키지 아니할 것

보조참가로 인하여 소송절차를 현저하게 지연시키는 경우에는 보조참가가 허용되지 아니한다(민소 71조 단서). 참가이유는 인정되지만 재판을 지연하거나 심리를 방해할 목적으로 통상의 법정에서는 재판을 진행할 수 없을 정도의 다수인이 보조참가신청을 하는 경우, 피고와의 통모 하에 소송절차를 지연시킬 의도로 뒤늦게 보조참가신청을 하는 경우 등이 여기에 해당될 수 있다.

다만 일반적으로 보조참가가 이루어지게 되면 어느 정도의 절차지연과 비용증가가 따르게 되는 것은 부득이하며 이와 같은 경우까지 금지하는 취지는 아니라고 할 것이므로, 보조참가로 인하여 소송절차를 ‘현저하게’ 지연시키는 경우로 한정하여 해석하여야 할 것이다.

3. 사무처리

가. 참가신청과 접수

보조참가에는 소에 관한 규정이 적용되지 않으므로 참가신청은 서면 또는 말 어느 쪽으로든 할 수 있다(민소 161조). 보조참가신청에는 참가의 취지(누구를 위하여 보조참가하는지)와 이유(소송의 결과에 대한 이해관계의 내용)를 명시하여야 한다(72조 1항). 다만 당사자의 이의신청이나 법원의 소명요구가 없는 한 참가이유를 소명할 필요는 없다(73조).

참가신청은 참가인으로서 할 수 있는 소송행위와 동시에 할 수 있다(민소 72조 3항).

보조참가신청에는 인지를 붙이지 아니한다(인지액·편철방법예규).

서면에 의한 참가신청이 있는 경우에는 그 신청서를 문건으로 전산입력하고, 신청서와 관계서류를 본기록에 가철한다(인지액·편철방법예규). 사건번호

를 따로 부여하지 않음은 물론이다. 참가신청이 접수되면 기록표지에 참가인의 표시를 하여야 한다.

참가신청서는 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다(민소 72조 2항). 기일외에서 말로 보조참가신청을 하여 법원사무관등이 이를 접수하여 조서에 기재한 때에도 마찬가지로 그 조서의 등본을 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다. 말로 보조참가신청을 한 경우에 조서등본 송달은 민사소송법 72조 2항이 규정하고 있지는 않지만 제도의 취지에 따라 당연히 행하여야 할 사항이다. 변론기일에 말로 보조참가신청을 한 경우에는 그 기일에 불출석한 당사자에게만 조서등본을 송달하면 될 것이다.

보조참가신청의 취하에 관하여는 아무런 규정이 없지만 소의 취하의 규정(민소 266조)을 유추하여 참가신청의 취하는 소송의 어느 단계에서도 허용된다. 다만 참가신청의 취하는 피참가인 및 그 상대방의 이익을 해하지 않고 취하 후에도 참가적 효력을 받게 되므로 어느 당사자의 동의도 필요하지 않다.

나. 참가신청에 대한 이의신청과 허부의 재판

(1) 이의신청이 있는 경우

참가신청에 대하여는 피참가인의 상대방은 물론 피참가인 자신도 이의신청을 할 수 있다. 다만 이의신청 없이 변론하거나 변론준비기일에서 진술한 때에는 이의신청권을 상실한다(민소 74조). 나아가 소송고지(84조)에 의하여 참가한 경우에 고지한 당사자는 미리 이의신청권을 포기한 것으로 볼 것이므로 이의신청을 할 수 없다. 이 이의신청도 물론 서면(문건으로 전산입력) 또는 말로 할 수 있고, 인지를 붙이지 아니한다(인지액·편철방법예규).

이의신청이 있으면 참가인은 참가의 이유를 소명하여야 하며, 법원은 참가를 허가하거나 허가하지 않는 결정을 하여야 한다(민소 73조 1항). 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(3항). 다만 결정이 아닌 종국판결로 심판하더라도 위법한 것은 아니다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2005두15700 판결).

이와 같이 종국판결로 심판하는 경우에는 판결이유에서 그 당부를 판단하였더라도 주문에 설시가 없으면 그에 대한 재판은 누락된 것으로 보게 되어 그 부분 소송은 여전히 그 심급에 계속 중으로서 적법한 상소의 대상이 되지 아니하므로, 판결주문에서 누락하지 않도록 주의하여야 한다.

이의신청이 있더라도 본 소송의 절차는 정지되지 않으며, 불허결정이 있어도 그 확정 시까지는 참가인으로서의 소송행위를 제한 없이 할 수 있다(민소 75조 1항). 위 허부 결정에 대한 즉시항고가 있을 때에는 역시 소송절차가 정지되지 않고, 기본절차에 관한 기록의 등본을 만들어 항고법원에 송부하여야 하며 기록 전체를 송부하여서는 안 된다(재일 80-3 1책의 기록에 관하여 수개의 절차에서 동시에 소송이 계속하게 되는 때의 처리요령).

참가불허의 결정이 확정되면 그때까지 참가인이 한 소송행위는 효력을 잃게 되지만, 피참가인이 원용하면 그 효력이 유지된다(민소 75조 2항).

(2) 이의신청이 없는 경우

보조참가의 요건에 관하여는 당사자의 이의신청 유무에 관계없이 법원이 직권으로 조사한다. 법원은 참가인의 당사자능력·소송능력이나 대리권의 존부(대리인에 의한 참가의 경우)와 같은 인적 요건뿐만 아니라 참가 이유나 방식과 같은 요건에 관하여도 직권으로 조사하여야 한다. 조사한 결과 참가 이유에 대하여 소명이 필요하다고 인정되면 직권으로 참가인에게 참가의 이유를 소명하도록 명할 수 있으며, 참가의 이유가 있다고 인정되지 아니하는 때에는 참가를 허가하지 아니하는 결정을 하여야 하는데(민소 73조 2항), 실무상 각하 결정을 하는 것이 일반적이다. 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(3항).

조사결과 보조참가신청이 적법하고 참가의 이유도 인정되는 경우 별도의 허가결정을 할 필요는 없다. 이의신청이 있는 경우에는 허가하는 경우에도 반드시 결정을 하여야 하는 것(민소 73조 1항)과 다른 점이다.

다. 심 리

(1) 보조참가인의 지위

보조참가인은 당사자가 아니라 보조자에 불과하므로 증인이나 감정인이 될 수 있다.

보조참가인은 대리인이 아니라 독자적인 소송관여권이 있으므로 기일통지나 송달도 피참가인과 별도로 참가인에게 빠짐없이 행하여야 한다. 판결을 보조참가인에게도 송달해야 함은 물론이다.

참가인이 기일에 출석하여 변론하면 피참가인은 결석하더라도 기일 불출석의 불이익을 입지 않는다.

참가인에게 소송절차 중단사유가 발생하더라도 본소의 소송절차는 중단되지 아니하고 참가인의 승계인이 수계하는 절차만 남게 된다(대법원 1995. 8. 25. 선고 94다27373 판결).

(2) 보조참가인이 할 수 있는 소송행위

보조참가인은 원칙적으로 모든 소송행위를 할 수 있다. 사실을 주장하거나 다룰 수 있고 증거신청, 상소제기, 이의신청 등에 제한이 없는 것이 원칙이다(민소 76조 1항 본문).

그러나 다음의 행위는 할 수 없고, 하더라도 무효이다.

① 소송 진행의 정도에 따라 피참가인도 할 수 없는 행위(민소 76조 1항 단서)

실기한 공격방어방법의 제출, 이의권을 포기·상실한 행위에 대한 이의, 피참가인이 본안변론을 하여 변론관할이 생긴 뒤의 관할위반의 항변, 상고심에서 참가한 경우 새로운 사실의 주장이나 새로운 증거의 제출 등을 할 수 없다. 또한 참가인은 피참가인의 상소제기기간이 경과한 후에는 상소를 제기할 수 없다(대법원 2001. 2. 9. 선고 99두5030 판결). 피참가인의 상고이유서제출기간이 지난 후에 제출한 보조참가인의 상고이유서도 부적법하다(대법원 1962. 3. 15. 선고 4294행상145 판결).

② 피참가인의 행위와 어긋나는 행위(민소 76조 2항)

피참가인의 소송행위와 보조참가인의 소송행위가 서로 어긋나는 경우에는 피참가인의 의사가 우선된다. 그러므로 피참가인은 참가인이 제기한 상소를 포기 또는 취하할 수 있으나(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다38168 판결), 참가인이 피참가인의 자백을 부인하거나, 피참가인이 상소권을 포기하거나 상소를 취하한 뒤 상소를 제기하는 것은 효력이 없다.

다만 참가인의 소송행위가 피참가인의 행위에 명백히 어긋나지 않고 소극적으로만 어긋나는 때에는 무효로 되지 않는다. 예를 들어 피참가인이 상소의 의사가 없더라도 상소권을 포기하지 않는 한 참가인이 상소할 수 있고(대법원 1999. 7. 9. 선고 99다12796 판결), 피참가인이 명백히 다투지 아니하여 민사소송법 150조에 의하여 그 사실을 자백한 것으로 보게 될 경우라도 참가인이 보조참가를 신청하면서 그 사실을 다룰 수 있다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007다53310 판결).

③ 피참가인에게 불이익한 행위

청구의 포기·인낙, 소송상 화해, 상소권의 포기, 피참가인이 제기한 상소의 취하, 자백, 이의권의 포기 등은 허용되지 않는다.

그러나 보조참가인의 증거신청행위가 피참가인의 소송행위와 어긋나지 아니하고 그 증거들이 적법한 증거조사절차를 거쳐 법원에 현출되었다면 법원이 이들 증거에 터 잡아 피참가인에게 불이익한 사실을 인정하였다 하여 그것이 민사소송법 76조 2항에 위배된다고 할 수 없다(대법원 1994. 4. 29. 선고 94다3629 판결).

④ 소송물을 처분·변경하는 행위

소의 변경, 소의 취하, 반소, 중간확인의 소 등의 제기는 허용되지 않는다.

⑤ 사법상의 권리행사

참가인은 소송수행상 필요하고 적절하다고 하여도 피참가인이 가진 사법상의 권리, 예를 들어 상계권, 취소권, 해지·해제권 등을 행사할 수 없다.

다만 피참가인이 재판외에서 실체법상의 권리를 행사하였으나 피참가인이 소송상 그와 같은 사실을 주장하지 않을 때에는 참가인이 이를 원용하여 주장할 수 있다.

라. 판결의 참가인에 대한 효력

보조참가가 있는 경우의 판결은 특별한 경우를 제외하고는 참가인에게도 그 효력이 미치는데(민소 77조), 이때의 판결의 효력은 기판력이 아니라 피참가인이 패소한 경우 보조참가인과 피참가인 사이에 서로 그 판결이 부당하다고 주장할 수 없는 구속력, 이른바 참가적 효력일 뿐이다(대법원 1979. 6. 12. 선고 79다487 판결, 대법원 1988. 12. 13. 선고 86다카2289 판결).

보조참가신청이 취하되어도 참가적 효력의 발생에는 영향이 없으나(대법원 1974. 6. 4. 선고 73다1030 판결), 신청각하결정을 한 때에는 참가적 효력이 미치지 않는다.

참가적 효력은 판결주문 중의 소송물에 대한 판단만이 아니라, 확정판결의 결론의 기초가 된 사실상 및 법률상의 판단으로서 보조참가인이 피참가인과 공동이익으로 주장하거나 다룰 수 있었던 사항에 대한 판단에도 미치지 않지만, 확정판결에 필수적인 요소가 아니어서 결론에 영향을 미칠 수 없는 부가적 또는 보충적인 판단이나 방론 등에까지 미치는 것은 아니다(대법원 1997. 9. 5. 선고 95다42133 판결). 확정판결이 아닌 화해권고결정에 의하여 종료된 경우에는 확정판결에서와 같은 법원의 사실상 및 법률상의 판단이 이루어졌다고 할 수 없으므로 참가적 효력이 인정되지 아니한다(대법원 2015. 5. 28. 선고 2012다78184 판결).

다음의 경우에는 판결의 참가적 효력이 미치지 않는다.

- ① 참가할 때의 소송진행 정도에 따라 참가인이 소송행위를 할 수 없거나, 그 소송행위가 효력을 가지지 아니하는 경우(민소 77조 1호)

상고심에서 참가한 경우에는 사실자료를 제출할 수 없으므로 판결의 사실

인정에 구속되지 않는다.

참가인이 상소를 제기하였지만 피참가인이 상소를 포기하여 상소의 효력이 발생하지 않은 경우에는 이후 참가인과 피참가인 사이의 소송에 있어서 피참가인이 어긋나는 행위를 하지 않았다면 판결 결과가 달라질 수 있었다는 것을 주장하여 참가적 효력에서 면제될 수 있다.

② 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 경우(민소 77조 2호)

피참가인이 청구의 포기·인낙을 하여 참가인의 소송수행 가능성이 박탈된 경우(대법원 1988. 12. 13. 선고 86다카2289 판결), 참가인이 부인한 사실을 피참가인이 자백한 경우(대법원 1974. 6. 4. 선고 73다1030 판결), 참가인이 제기한 상소를 취하하거나 참가인이 신청한 증인을 철회한 경우 등에는 참가인은 이와 같은 소송행위를 할 수 있었다면 판결 결과가 달라졌을 것이라는 것을 주장하여 참가적 효력에서 면제될 수 있다.

③ 피참가인이 참가인이 할 수 없는 소송행위를 고의 또는 과실로 하지 않은 경우(민소 77조 3호)

참가인에게 알려지지 않은 유리한 사실 또는 증거를 주장·제출하지 않은 경우, 피참가인만이 행사할 수 있는 사법상의 권리 행사를 태만히 한 경우 등에도 참가인은 피참가인이 이러한 행위를 하였으면 소송결과가 달라졌을 것임을 주장하여 참가적 효력을 면제받을 수 있다.

마. 소송비용

보조참가로 인한 소송비용에 대하여 당사자에 준하여 소송비용 부담을 하도록 정하고 있다(민소 103조). 따라서 소송비용의 부담에 관한 주문에 '보조참가로 인한 부분'을 특정하지 않은 채 패소한 당사자가 부담한다는 취지만 기재되어 있더라도, 피참가인이 전부 승소한 경우에는 당연히 패소한 당사자가 보조참가로 인한 소송비용까지도 부담하는 것으로 볼 수 있으나 피참가인이 일부 승소하였음에도, 주문에 '보조참가로 인한 부분'이 특정되지 않

은 채 피참가인과 상대방 당사자 사이의 소송비용 부담 비율만 기재되어 있다면, 여기에는 보조참가로 인하여 생긴 부분까지 당연히 포함되었다고 볼 수 없어 이에 관한 소송비용의 재판이 누락된 경우에 해당한다(대법원 2022.

4. 5. 자 2020마7530 결정).

바. 기타 효과

소송에서 보조참가인으로 참가하여 상대방의 주장을 적극적으로 다투고 자신의 권리를 주장하면서 권리 위에 잡자는 것이 아님을 표명한 경우에는 소멸시효 중단사유로서의 재판상 청구로 볼 수 있다(대법원 2012. 2. 9. 선고 2011다20034 판결, 대법원 2014. 4. 24. 선고 2012다105314 판결).

제3절 공동소송적 보조참가

1. 의 의

‘공동소송적 보조참가’라 함은 재판의 효력이 제3자(참가인)에게 미치는 경우에 그 제3자가 하는 보조참가를 말한다(민소 78조). 예컨대 채권자대위소송에 있어서의 채무자, 행정소송에서 판결의 효력이 참가인에게 미치는 경우, 선정당사자에 의한 소송에 있어서 선정자 등이 보조참가하는 경우가 공동소송적 보조참가에 해당한다. 위와 같은 경우 소송이 이미 제기되어 있는 이상 채무자·행정처분 관련자·선정자 등이 참가에 의하여 소를 제기하는 것은 중복제소의 금지에 저촉되기 때문에 공동소송참가는 허용되지 않고 공동소송적 보조참가만이 가능하다.

공동소송적 보조참가로서 취급할 것인가의 여부는 당사자의 신청에 구애될 것이 아니고 법원이 법령의 해석에 의하여 결정할 성질의 것이다(대법원 1962. 5. 17. 선고 4294행상172 판결).

보통의 보조참가와 구별하여 공동소송적 보조참가제도를 인정하는 이유는 판결의 효력을 받는 제3자를 위해서는 보통의 보조참가보다 훨씬 강한(필수적 공동소송인에 준하는) 소송수행권을 부여할 필요가 있기 때문이다. 판결의 효력을 받는 제3자가 자기 이익을 지키려면 형성소송에 있어서의 소제기간(예컨대 상법 376조, 행소 20조) 도과 전에는 공동소송참가를 할 수 있으나, 그 기간 후에는 본소청구에 관한 원·피고적격이 없으므로 공동소송적 보조참가를 할 수밖에 없다.

공동소송적 보조참가인은 독립된 당사자적격을 가지지 아니한다는 점에서 민사소송법 83조의 공동소송참가와 구별된다.

2. 사무처리

가. 참가신청과 접수 및 참가에 대한 이의 등

이에 관하여는 보통의 보조참가와 같으므로 보조참가에 관한 해당 부분의 설명과 같다.

나. 심 리

공동소송적 보조참가인의 지위라든가 그가 할 수 있는 소송행위 등도 대체로 통상의 보조참가의 경우와 동일하나, 공동소송적 보조참가인은 판결의 효력을 받는 지위에 있다는 점에서 필수적 공동소송에 관한 민사소송법 67조 및 69조가 준용된다(민소 78조).

① 참가인이나 피참가인 가운데 한 사람이 한 유리한 소송행위는 모두를 위하여 효력이 생기나, 불리한 소송행위는 모두 함께 하지 아니하면 효력이 생기지 아니하므로(민소 67조 1항), 피참가인의 소송행위가 참가인에게 불이익이 되는 것은 효력이 없다. 예컨대 참가인이 상소를 한 경우에 피참가인이 상소포기 또는 상소취하를 하여도 참가인의 상소는 그 효력이 지속된다(대법원 1967. 4. 25. 선고 66누96 판결, 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두36836 판

결). 다만 소를 취하하면 소가 처음부터 계속되지 아니한 것으로 간주될 뿐으로서 재판의 효력과는 직접적인 관련이 없는 소송행위이므로 피참가인이 참가인의 동의 없이 소를 취하하더라도 이는 유효하다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2011두13729 판결). 그러나 소취하와 달리 재심의 소를 취하하는 것은 확정된 종국판결에 대한 불복의 기회를 상실하게 함으로써 재판의 효력과 직접적인 관련이 있는 소송행위이므로 참가인이 참가한 후에는 피참가인이 재심의 소를 취하하더라도 참가인의 동의가 없는 한 효력이 없다(대법원 2015. 10. 29. 선고 2014다13044 판결).

② 상대방의 소송행위는 참가인에게 하더라도 피참가인에 대하여 효력이 있다(민소 67조 2항).

③ 참가인에게 소송절차의 중단 또는 중지의 사유가 생기면 소송절차는 정지된다(민소 67조 3항).

④ 참가인이나 피참가인 가운데 한 사람이 상소를 제기한 경우에 다른 참가인이나 피참가인이 그 상소심에서 하는 소송행위에는 민사소송법 56조 1항의 규정이 준용되므로 그 법정대리인이 소송행위를 하는 경우에 후견감독인으로부터 특별한 권한을 받을 필요가 없다(민소 69조).

⑤ 참가인은 피참가인의 행위와 저촉되는 행위를 할 수 있다(민소 76조 2항의 적용배제). 따라서 참가인은 피참가인의 청구의 인낙이나 자백에 대하여 이의하여 무효화시킬 수 있다.

⑥ 참가인의 상소기간은 참가인에 대한 판결송달 시로부터 독립하여 계산된다.

⑦ 참가인은 당사자가 아니므로 통상의 보조참가인과 같은 지위를 가지는 것에 불과하여 청구의 포기·인낙, 화해, 조정 또는 소의 취하, 변경, 피참가인이 제기한 상소의 취하 등 처분행위를 할 수 없다. 상고하지 않은 공동소송적 참가인이 피참가인의 상고이유서 제출기간이 지난 후 상고이유서를 제출하였다면 적법한 기간 내에 제출한 것으로 볼 수 없고, 이러한 법리는 상

고이유의 주장에 대해서도 마찬가지여서, 상고하지 않은 참가인이 적법하게 제출된 피참가인의 상고이유서에서 주장되지 않은 내용을 피참가인의 상고이유서 제출기간이 지난 후 제출한 서면에서 주장하였더라도 이는 적법한 기간 내에 제출된 상고이유의 주장이라고 할 수 없다(대법원 2020. 10. 15. 선고 2019두40611 판결).

제4절 독립당사자참가

1. 의 의

‘독립당사자참가’라 함은 타인 간의 소송계속 중에 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽을 상대방으로 하여 그 소송과 관련된 자기의 청구에 대하여 동시에 심판을 구하기 위하여 하는 소송참가를 말한다(민소 79조 1항).

독립당사자참가는 당사자로서 참가한다는 점에서 기존 당사자의 승소를 돕는 데에 불과한 보조참가와 구별되고, 당사자로서 참가를 하더라도 기존의 어느 일방 당사자와 공동소송이 되지 않고 독립된 제3의 당사자가 된다는 점에서 공동소송참가와 구별된다.

독립당사자참가는 소송 중의 소의 일종으로서 이에 의하여 원고·피고·참가인 사이의 분쟁을 한꺼번에 모순 없이 해결할 수 있다는 점에 그 존재의 의가 있으므로, 이러한 합일확정을 위하여 소송진행과 재판자료의 통일에 관한 고유필수적 공동소송의 특칙(민소 67조)이 준용된다.

2. 요 건

가. 타인 간에 소송이 계속 중일 것

보조참가인은 본소송의 제3자이므로 독립당사자참가를 할 수 있고, 그때에는 보조참가가 종료된다(대법원 1993. 4. 27. 선고 93다5727, 5734 판결).

소송이라 함은 판결절차 또는 이에 준하는 절차를 의미하며, 독촉절차의 경우에는 채무자의 이의제기로 판결절차로 넘어간 후에 제기할 수 있다.

사실심에 계속 중인 한 항소심에서도 할 수 있다. 독립당사자참가는 실질에 있어서 소제기의 성질을 가지므로 상고심에서는 할 수 없다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93다43682 판결).

나. 참가의 이유가 있을 것

독립당사자참가인이 수 개의 청구를 병합하여 독립당사자참가를 하는 경우에는 각 청구별로 아래의 독립당사자참가의 요건을 갖추어야 하고, 참가인이 독립당사자참가의 요건을 갖추지 못한 청구를 추가하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다241608, 241615 판결).

(1) 소송목적의 전부 또는 일부가 자기의 권리임을 주장할 것(권리주장 참가)

원고가 본소에서 주장하는 권리와 참가인이 주장하는 권리가 논리적으로 양립할 수 없는 관계에 있어야 한다. 예컨대 원고의 소유권에 기한 인도 청구에 대하여 참가인도 소유권을 주장하는 경우가 전형적인 예일 것이나, 배타성과 대세적 효력이 있는 물권뿐만 아니라 채권의 경우에도 논리적으로 양립할 수 없는 경우에는 독립당사자참가가 가능하다.

참가신청에서 주장한 내용 자체에서 원고가 주장하는 권리와 참가인이 주장하는 권리가 양립할 수 없는 관계에 있다면 비록 본안에 들어가 심리한 결과 참가인의 권리가 인정되지 않더라도 이는 참가인의 청구가 이유 없는 사유가 될 뿐 참가신청이 부적법하게 되는 것은 아니다(대법원 1992. 12. 8. 선고 92다26772, 26789 판결). 참가인의 청구는 주장 자체에 의하여 성립할 수 있음을 요한다(대법원 1993. 4. 27. 선고 93다5727, 5734 판결, 대법원 2001. 9. 28. 선고 99다35331, 35348 판결).

독립당사자참가인의 권리 또는 법률상의 지위가 원고로부터 부인당하거나 또는 그와 저촉되는 주장을 당함으로써 위협을 받거나 방해를 받는 경우에

는 독립당사자참가인은 원고를 상대로 자기의 권리 또는 법률관계의 확인을 구하여야 하고, 원고 주장의 그 제3자에 대한 권리 또는 법률관계가 부존재한다는 것만의 확인을 구하는 것은 확인의 이익이 없다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2010다54535 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다74192 판결, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2009다71312 판결).

참가하려는 소송에 수 개의 청구가 병합된 경우 그중 어느 하나의 청구라도 독립당사자참가인의 주장과 양립하지 않는 관계에 있으면 그 본소청구에 대한 참가가 허용된다(대법원 2007. 6. 15. 선고 2006다80322, 80339 판결).

(2) 소송결과에 따라 자기의 권리가 침해됨을 주장할 것(사해방지참가)

사해방지를 위한 독립당사자참가의 경우 원고와 피고가 당해 소송을 통하여 제3자를 해할 의사, 즉 사해의사를 가지고 있고 그 소송의 결과 제3자의 권리 또는 법률상 지위가 침해될 염려가 있다고 인정되면 충분하고, 참가인의 청구가 원고의 청구와 반드시 논리상 양립할 수 없는 관계에 있어야 하는 것은 아니다(대법원 1996. 3. 8. 선고 95다22795 판결). 이러한 사해의사는 객관적으로 인정할 수 있어야 한다(대법원 2001. 8. 24. 선고 2000다12785 판결).

사해행위취소의 상대적 효력에 의하면, 원고의 피고에 대한 청구의 원인 행위가 사해행위라는 이유로 원고에 대하여 사해행위취소를 청구하면서 독립당사자참가신청을 하는 경우, 독립당사자참가인의 청구가 그대로 받아들여진다 하더라도 원고와 피고 사이의 법률관계에는 아무런 영향이 없고, 따라서 그러한 참가신청은 사해방지참가의 목적을 달성할 수 없으므로 부적법하다(대법원 2014. 6. 12. 선고 2012다47548 판결).

다. 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽에 대하여 청구를 할 것

참가인이 본소송의 원고와 피고 양쪽을 모두 상대방으로 하여 청구를 할 수도 있고, 그중 한쪽에 대하여만 청구를 할 수도 있다(민소 79조 1항).

라. 소의 병합요건을 갖출 것

독립당사자참가로 인하여 하나의 절차에서 여러 개의 청구를 병합하여 심판하게 되므로 참가인의 청구가 본소 청구와 같은 종류의 소송절차에서 심판될 청구이어야 하고(소송절차의 공통, 민소 253조), 참가인의 청구가 본소 청구와 다른 법원의 전속관할에 속하여서는 안 된다.

마. 일반적 소송요건을 갖출 것

참가신청은 새로운 소제기와 같으므로 당사자능력, 당사자적격, 중복제소, 기판력 등에 관한 일반적인 소송요건을 갖추어야 한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다12517 판결).

3. 사무처리

가. 신청 및 접수

참가신청은 소의 일종이므로 소액사건을 제외하고는 반드시 서면에 의하여야 하고(민소 248조, 소액 4조), 그 서면에는 참가의 취지와 이유를 명시하며(민소 79조 2항, 72조 1항), 소장의 필수적 기재사항(249조)을 기재하여야 한다.

참가신청서에는 심급에 따라 소장·항소장에 준하는 인지를 붙여야 한다(인지 6조 1항). 당사자가 상소제기를 하지 아니하는 경우에는 참가인이 상소제기와 동시에 참가신청을 할 수 있다(민소 79조 2항, 72조 3항). 송달료도 소제기의 경우에 준하여 처리한다.

참가신청서가 접수되면 민사사건으로 전산입력하고, 독립된 사건번호를 부여함과 동시에 사건명을 붙이며, 그 신청서와 관계서류를 본기록에 합철한다(인지액·편철방법예규). 이 경우 기록표지의 '사건번호'란에는 위 사건번호를 병기하고 괄호 안에 참가의 표시를 부기하여야 하며[예: 20〇〇가합100(참가)], '사건명'란에도 사건명을 병기하여야 한다. 또한 기록표지의 맨 아랫

단 빈칸에 ‘당사자참가인’이라고 기재하고 이름을 기재하여야 한다.

재판장은 접수된 참가신청서에 대한 심사를 하여 인지의 부족 등 흠이 있으면 보정을 명하고 이에 불응하면 명령으로 참가신청서를 각하하여야 한다. 흠이 없다고 인정되면, 편면적 참가인지 여부에 관계없이 양쪽 당사자에게 지체 없이 신청서 부분을 송달하여야 한다(민소 79조 2항, 72조 2항, 민소규 64조 2항).

나. 심 리

참가신청이 있으면 참가의 요건 구비 여부를 직권으로 심리하여 구비하지 않은 때에는 각하의 판결을 하여야 하는데 이 각하판결은 종국판결과 함께 하여야 한다.

본안심리에 있어서 당사자 3인 중 2인 간의 소송행위가 다른 1인에게 불이익이 될 때에는 효력이 생기지 않는다(민소 79조 2항, 67조 1항). 예를 들면 어느 2인 간의 청구의 포기·인낙, 화해(대법원 2005. 5. 26. 선고 2004다 25901 판결), 상소취하, 자백(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다9030, 9047 판결) 등은 타인에게 불이익한 한 무효가 된다. 다만 본소의 취하나 참가신청의 취하는 무방하다. 이에 반하여 유리한 소송행위는 나머지 1인에 대하여도 효력이 생긴다(79조 2항, 67조 2항).

기일은 반드시 공통으로 정하여야 하며 어느 1인에 생긴 소송절차의 중단·중지의 사유는 전원에 대하여 효력이 있다(민소 79조 2항, 67조 3항). 변론의 분리도 허용되지 않는다.

당사자 및 참가인 사이에 본안에 관한 합일확정을 목적으로 하는 것이 독립당사자참가제도이므로 판결에 있어서는 반드시 하나의 전부판결로 원고의 청구와 참가인의 청구에 대하여 한꺼번에 재판하여야 한다. 당사자 일부에 관하여서만 판결을 하거나 추가판결을 하는 것은 모두 허용되지 않는다(대법원 1995. 12. 8. 선고 95다44191 판결). 항소심재판장의 항소장 각하명령은 항

소장 송달 전까지만 가능하므로, 독립당사자참가소송의 제1심 본안판결에 대해 일방이 항소하고 피항소인 중 1명에게 항소장이 적법하게 송달되어 항소심법원과 당사자들 사이의 소송관계가 일부라도 성립한 것으로 볼 수 있는 경우, 항소심재판장이 단독으로 항소장 각하명령을 할 수 없다(대법원 2020. 1. 30. 자 2019마5599, 5600 결정).

참가인이 참가신청 각하의 판결을 받았음에도 불구하고 불복상소를 하지 않는 경우 다른 패소당사자의 상소에도 불구하고 참가인에 대한 판결부분이 분리·확정되고 참가부분은 이탈되어 본소만 남게 된다. 그러나 제1심에서 원고 및 참가인 패소, 피고 승소의 본안판결이 선고된 데 대하여 원고만이 항소한 경우, 실제로 상소를 제기하지도 당하지도 않은 참가인에 대한 판결 부분도 확정이 차단되고 그에 관한 소송관계가 이심되어 항소심의 심판대상이 되므로 항소심으로서의 참가인의 원고·피고에 대한 청구에 대하여도 같은 판결로 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 22. 선고 90다19329 판결).

이와 같이 패소자 중 1인이 상소하면 다른 패소자에게도 상소의 효력이 미쳐, 판결 전부에 대하여 확정이 차단되고 사건은 상소심으로 이심되는데, 이 경우 패소하고 상소하지 아니한 당사자의 상소심에서의 지위가 문제된다. 이에 대하여 판례는 독립당사자참가인의 청구와 원고의 청구가 모두 기각되고 원고만이 항소한 경우 독립당사자참가인도 항소심에서의 당사자라 하여, 상소인도 피상소인도 아닌 단순한 '상소심 당사자'라고 보고 있다(대법원 1981. 12. 8. 선고 80다577 판결). 따라서 상소취하권이 없고, 상소장에 인지를 붙일 의무가 없다.

이러한 경우 항소심의 심판대상은 실제 항소를 제기한 자의 항소취지에 나타난 불복범위에 한정하되 위 세 당사자 사이의 결론의 합일확정의 필요성을 고려하여 그 심판의 범위를 판단하여야 하고, 이에 따라 항소심에서 심리·판단을 거쳐 결론을 내림에 있어 위 세 당사자 사이의 결론의 합일확정을 위하여 필요한 경우에는 그 한도 내에서 항소 또는 부대항소를 제기한

바 없는 당사자에게 결과적으로 제1심판결보다 유리한 내용으로 판결이 변경되는 것도 배제할 수는 없다(대법원 2007. 10. 26. 선고 2006다86573 판결). 그러나 판결 결론의 합일확정을 위하여 항소 또는 부대항소를 제기한 적이 없는 당사자의 청구에 대한 제1심판결을 취소하거나 변경할 필요가 없다면, 항소 또는 부대항소를 제기한 적이 없는 당사자의 청구가 항소심의 심판대상이 되어 항소심이 그 청구에 관하여 심리·판단해야 하더라도 그 청구에 대한 당부를 반드시 판결 주문에서 선고할 필요가 있는 것은 아니고 이와 같이 항소 또는 부대항소를 제기하지 않은 당사자의 청구에 관하여 항소심에서 판결 주문이 선고되지 않고 독립당사자참가소송이 그대로 확정된다면, 취소되거나 변경되지 않은 제1심판결의 주문에 대하여 기판력이 발생한다(대법원 2022. 7. 28. 선고 2020다231928 판결).

한편 독립당사자참가소송에서 원고승소 판결에 대하여 참가인만이 상소를 했음에도 상소심에서 원고의 피고에 대한 청구인용 부분을 원고에게 불리하게 변경할 수 있는 것은 참가인의 참가신청이 적법하고 나아가 합일확정의 요청상 필요한 경우에 한하므로, 참가인의 참가신청을 각하한 제1심판결에 대하여 참가인만이 항소하였는데 참가인의 항소를 기각하면서 제1심판결 중 피고가 항소하지도 않은 본소 부분을 취소하고 원고의 피고에 대한 청구를 기각하는 것은 부적법하다(대법원 2007. 12. 14. 선고 2007다37776 판결).

4. 독립당사자참가소송의 해소(단일소송 또는 공동소송으로 환원)

가. 본소의 취하 또는 각하

본소의 취하에는 피고는 물론 참가인의 동의가 필요하다.

본소가 취하되거나 부적법 각하되는 경우 참가인의 원고 및 피고에 대한 공동소송이 남게 되거나(공동소송잔존설, 취하의 경우 같은 뜻의 대법원 1991. 1. 25. 선고 90다4723 판결), 참가인의 원고 또는 피고에 대한 단일소송만이 남게 된다.

나. 참가신청의 취하 또는 각하

참가인은 소의 취하에 준하여 참가신청을 취하할 수 있다. 따라서 원고나 피고가 본안에 관하여 응소한 경우에는 참가의 상대방 당사자의 동의를 필요로 한다(대법원 1981. 12. 8. 선고 80다577 판결). 독립당사자참가인이 소송탈퇴서를 제출한 것은 그 참가신청을 취하한 취지라고 보아야 한다(대법원 2010. 9. 30. 선고 2009다71121 판결).

참가신청이 취하되거나 부적법 각하되면 물론 참가 이전의 상태로 환원되어 본소만이 남게 된다. 참가인이 원고·피고 중 어느 한쪽에 대한 청구만을 취하하거나 참가신청 중 어느 한쪽의 청구만이 부적법 각하되면 편면참가의 소송형태가 될 것이다.

다. 소송탈퇴

참가가 있음으로써 종래의 원고 또는 피고가 더 이상 소송을 계속할 필요가 없게 된 때에는 상대방(즉 피고 또는 원고)의 승낙을 얻어 탈퇴할 수 있다(민소 80조 본문). 탈퇴하는 사람은 잔존자(자기의 종전 상대방과 참가인) 사이의 소송결과에 전면 승복할 의사로 소송에서 물러서는 것이다. 따라서 탈퇴가 있으면 본소의 소송관계와 참가인·탈퇴자 간의 소송관계는 각 종료되고 참가인과 상대방과의 소송관계만 남게 된다. 이때 참가인의 동의는 불필요하다.

탈퇴의 의사표시는 서면에 의하는 것이 원칙이나 변론기일에서는 말로 할 수 있다. 상대방의 승낙도 마찬가지이다. 다만 소의 취하에 있어서와 같은 동의간주(민소 266조 6항)는 인정되지 않는다. 탈퇴가 있을 때는 기록표지의 ‘당사자’란에 탈퇴의 취지와 일자를 부기한다. 소송탈퇴서 및 탈퇴동의서에는 인지를 붙이지 아니한다(인지액·편철방법예규).

판결은 탈퇴자에 대하여도 효력이 미친다(민소 80조 단서). 여기서 효력이라 함은 기판력과 집행력을 모두 포함한다는 것이 통설이다. 이 경우 탈퇴자

에 대한 강제집행 시 무엇이 집행권원이 되어야 하는지가 문제 된다. 잔존자 간의 판결과 탈퇴 시의 변론조서가 합쳐져서 집행권원이 된다는 견해 또는 탈퇴 시에 인낙조서에 준하는 탈퇴조서를 작성해 두었다가 나중에 판결이 나면 이를 조건성취의 증명으로서 첨부하여 집행권원이 된다는 견해가 있으나, 잔존자 간의 판결 자체의 주문에다가 탈퇴자의 이행의무를 선언하면 된다는 견해가 가장 무난할 것이다. 판결 주문에 탈퇴자에 대한 의무이행 선언이 누락되었다면 승소자가 추가판결을 신청할 수 있다. 판결에도 본소의 사건번호와 사건명 및 탈퇴당사자도 표시하되 탈퇴당사자 옆에 괄호하고 “탈퇴”라고 표시한다.

제5절 승계참가와 승계인수

1. 소송물의 양도

‘소송물의 양도’라 함은 소송계속 중에 소송물인 권리관계에 관한 당사자의 지위(당사자적격)가 특정적으로 제3자에게 이전되는 것을 말한다. 바꾸어 말하면 소송계속 중에 일반승계(상속·법인합병 등) 이외의 사유로 소송물에 관한 당사자적격이 이전되는 경우이다. 매매·증여·채권양도 등 임의처분은 물론 민사집행법상 매각·채권전부명령 등 법률상의 이전도 포함되고, 승계취득이든 원시취득(예컨대 시효취득)이든 관계없다. 또한 소송계속 중에 소송물의 양도가 이루어져야 하므로, 예컨대 청구이의의 소가 제기되기 전에 그 집행권원에 표시된 청구권을 양수한 사람의 청구이의의 소에 대한 권리승계 참가신청은 부적법하다(대법원 1983. 9. 27. 선고 83다카1027 판결).

2. 승계참가와 승계인수의 대비

소송물의 양도가 있는 경우에 관하여 민사소송법은 그 양수인이 스스로

소송에 참가하거나 또는 그 양수인을 당사자가 강제로 소송에 인수시키는 제도를 인정하고 있다. 전자가 승계참가(민소 81조)이고 후자가 승계인수(82조)이다. 그중 후자에 관하여 종래 실무에서는 ‘인수참가인’라는 용어를 사용해 왔고, 그에 따라 소송을 인수한 인수인을 ‘인수참가인’으로 호칭하였으나, ‘승계인의 소송참가’(81조)를 ‘승계참가’로 부르는 것에 대비되는 정확한 표현은 ‘승계인의 소송인수’(82조)에 해당하는 ‘승계인수’와 ‘승계인수인’이라고 할 수 있다.

권리의 양도가 있는 경우에 승계참가뿐만 아니라 승계인수도 가능하고, 또한 채무의 승계가 있는 경우에도 승계인수뿐만 아니라 승계참가를 할 수 있다(대법원 1983. 9. 27. 선고 83다카1027 판결). 채무의 승계인이라도 승소할 전망이 있으면 자발적인 참가를 바랄 것이기 때문에 채무승계의 경우에도 참가신청을 허용하고, 마찬가지로 권리승계의 경우에는 권리승계인이 소송상 패소 가능성이 높으면 참가를 꺼릴 것이기 때문에 권리승계의 경우에도 피참가인의 상대방에 의한 인수를 가능하게 하여야 하기 때문이다.

결국, 승계참가와 승계인수의 차이는 제3자 쪽에서 자발적으로 참가하는가(자발참가, 임의참가) 아니면 기존 당사자 쪽에서 제3자를 강제적으로 끌어들이는가(강제참가)에 있을 뿐, 권리·의무의 전부 또는 일부를 승계한다는 점에는 전혀 차이가 없다.

3. 사무처리

가. 승계참가의 경우

(1) 신청과 접수

승계참가신청은 독립당사자참가 신청방식에 따라서 한다(민소 81조). 따라서 반드시 서면에 의하여야 하며, 그 서면에는 참가의 취지와 이유를 명시하고(79조 2항, 72조 1항), 소장의 필수적 기재사항(249조)을 기재하여야 한다.

피참가인이 참가인의 승계주장사실을 다투지 아니하는 경우에는 권리승계

나 의무승계의 경우 모두 인지를 붙이지 아니하고, 신청서가 접수되면 문건으로 전산입력하며(인지액·편철방법예규), 별도의 사건번호는 부여하지 아니하고, 신청서와 관계서류를 본기록에 가철한다.

피참가인이 승계주장사실을 다투는 경우에는 독립당사자참가의 경우와 마찬가지로 민사소송 등 인지법 2조 및 6조에서 정한 금액 상당의 인지를 붙여야 하고, 민사사건으로 전산입력하며, 별도의 사건번호를 부여하고, 소송기록에 합철한다(인지액·편철방법예규).

기록표지에는 ‘승계참가인’란을 따로 만들어 그 성명과 대리인의 표시를 하고, 신청서의 부분은 지체 없이 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다(민소 81조, 79조 2항, 72조 2항, 민소규 64조 2항).

(2) 심 리

승계참가의 형식은 독립당사자참가와 같지만 소송의 구조에는 차이가 있다. 피참가인이 양도승계 사실을 다투지 않으면 권리승계참가인이 피참가인에 대하여 아무런 청구를 할 필요가 없으므로 삼면소송관계가 성립하지 않는다(대법원 1975. 11. 25. 선고 75다1257 판결). 원고가 승계참가인의 승계 여부에 대해 다투지 않으면서도 소송탈퇴, 소취하 등을 하지 않거나 이에 대하여 피고가 부동의하여 원고가 소송에 남아 있다면 승계로 인해 중첩된 원고와 승계참가인의 청구 사이에는 필수적 공동소송에 관한 민사소송법 제67조가 적용된다(대법원 2019. 10. 23. 선고 2012다46170 전원합의체 판결).

그러나 피참가인과 참가인 간에 양도의 유무나 효력에 관한 다툼이 있는 경우에는 독립당사자참가소송에 준하여 처리하고, 심리 결과 승계사실이 인정되지 않으면 본안판결을 하여야 한다.

참가신청은 소제기에 해당하고 참가요건(소송계속, 소송목적인 권리의 양수)은 소송요건에 해당하므로 참가요건에 흠이 있는 때(소송계속 중의 소송목적인 권리의 양수가 아닌 경우)에는 변론을 거쳐 판결로 참가신청을 각하하여야 하고, 이때 승계참가인의 부적법한 참가신청을 각하하는 판결을 반드시 원

래의 당사자 사이의 소송에 대한 판결과 함께 하여야 하는 것은 아니다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011다85789 판결).

공시송달로 진행된 제1심판결에 대하여 피고가 추후보완항소를 제기하고, 그 항소심에서 원고 승계참가를 한 경우, 피고가 제기한 추후보완항소가 부적법하다면 소송계속의 요건을 갖추었다고 볼 수 없으므로 원고 승계참가인의 참가신청은 부적법하고(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016다25300 판결), 건축허가취소처분 취소소송 중 당해 건물의 소유권을 이전받은 자가 원고 승계참가를 한 경우, 소송목적인 권리는 건축허가취소처분의 취소를 구하는 법률상 지위이므로 건축허가 대상이 되는 건물 소유권을 이전받은 것은 소송목적인 권리의 양수에 해당하지 않아 참가신청은 부적법하다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011두26718 판결).

다만 참가신청의 이유로 주장하는 사실관계 자체에서 승계적격의 흠이 명백하지 않는 한 승계인에 해당하는지 여부는 승계참가인의 청구의 당부와 관련하여 판단할 사항이므로, 심리 결과 승계사실이 인정되지 않으면 승계참가인의 청구를 기각하는 판결을 하여야지 승계참가신청을 각하하는 판결을 할 것은 아니다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2002다70211 판결, 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다67105 판결).

사실심 변론 종결 후에 변론의 재개신청을 함과 동시에 승계참가인의 승계참가신청이 있었던 경우, 사실심이 본래의 소송에 대하여 변론재개를 하지 않은 채 그대로 판결하는 한편, 참가신청에 대하여는 이를 분리하여 각하하는 판결을 하였더라도 위법은 아니다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004다26997 판결). 상고심에서는 승계참가가 허용되지 않는다(대법원 2001. 3. 9. 선고 98다51169 판결).

나. 승계인수의 경우

(1) 신청과 접수

당사자 쪽에서 승계인을 강제적으로 소송에 끌어들이는 제도이기 때문에 당사자가 소송인수의 신청을 하여야 한다. 여기서 당사자란 피참가인의 상대방만을 의미하는지, 아니면 피참가인 자신도 포함하는지에 관하여는 견해의 대립이 있으나, 통설은 피참가인에게도 신청권을 인정하고 있다.

인수신청의 방식에 관하여는 특별한 제한이 없으므로 서면 또는 말로 할 수 있다(민소 161조). 신청에는 인수를 구하는 범위와 이유를 분명히 하여야 한다. 인수를 구하는 내용이 피참가인에 대한 것과 동일한 때(이른바 교환적 인수)에는 단순히 인수를 구하는 것으로 충분하다. 반드시 소송의 목적인 채무와 동일한 채무를 승계한 때가 아니라도 분쟁이 제3자에 확대되어 이를 전제로 새로운 채무가 생기고 이에 대하여 제3자가 당사자적격을 취득한 경우(예를 들어 건물철거 및 토지인도청구 소송계속 중에 피고가 그 건물에 제3자를 입주시켰을 때 입주자에 대한 퇴거청구를 하는 경우)에도 소송인수를 허용한다는 견해가 유력한데, 이때에는 새로운 청구취지와 청구원인을 기재하여야 할 것이다. 한편 판례는 소송당사자가 제3자로 하여금 그 소송을 인수하게 하기 위하여서는 그 제3자가 소송계속 중 그 소송의 목적된 채무를 승계하였음을 전제로 하여 그 제3자에 대하여 인수한 소송의 목적된 채무이행을 구하는 경우에 허용되고 그 소송의 목적된 채무와는 전혀 별개의 채무의 이행을 구하기 위한 경우에는 허용될 수 없다고 한다(대법원 1971. 7. 6. 자 71다 726 결정).

권리의무를 승계한 자란 채권관계의 채무뿐만 아니라 특정물에 관한 물권적 청구권에 기한 이행소송의 계속 중에 목적물건을 양수한 자가 본조의 승계인에 해당함은 물론이다. 예컨대 토지소유권에 기한 가옥의 철거, 토지의 인도를 구하는 소송에서 그 가옥의 소유권을 양수한 자, 소유권에 기한 등기 말소청구소송의 계속 중에 당해 부동산을 매수하여 이전등기를 경료하거나

저당권을 설정받은 자 등은 승계인에 해당한다.

그러나 채권적 청구권에 기한 청구의 상대방에게서 채권채무 자체가 아니라 그 목적물을 승계한 경우, 예컨대 매매계약 등의 채권적 청구권에 기하여 매도인을 상대로 이전등기청구나 목적물인도청구를 하는 경우에 매도인으로 부터 별도의 등기이전을 받거나(대법원 1983. 3. 22. 자 80마283 결정) 점유를 승계한 자, 임대차의 임차인이 임대인에 대하여 목적물의 인도청구소송 중에 임대인으로 부터 매수하거나 임차한 자, 시효완성을 원인으로 소유권이전 등기청구소송 중 피고로부터 목적물을 매수하여 등기를 경료한 자는 승계인에 포함되지 않는다. 이와 같이 원고의 청구권이 채권적 청구권인 경우에는 원고는 피고로부터 등기 또는 점유를 이전받은 자에 대하여 대항할 수 있는 아무런 권원이 없어 패소를 면할 수 없으며, 따라서 인수의 이익이 없기 때문이다. 그러므로 구 도시 및 주거환경정비법의 주택재건축사업 시행자가 조합 설립에 동의하지 않은 토지 또는 건축물 소유자를 상대로 매도청구의 소를 제기하여 매도청구권을 행사한 이후 제3자가 매도청구 대상인 토지 또는 건축물을 특정승계한 경우, 사업시행자가 제3자로 하여금 매도청구소송을 인수하도록 신청할 수 없다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다255613 판결).

신청에 있어서의 당사자의 호칭은 인수신청인과 피인수신청인(제3자)이 될 것이다.

신청서에는 인지를 붙이지 아니하고, 서면에 의한 인수신청이 있을 때에는 그 신청서를 문건으로 전산입력하며(인지액·편철방법예규), 신청서와 관계 서류를 본기록에 가철한다. 요컨대 독립한 신청사건으로는 취급되지 않는 것이다.

주의할 점은 인수신청만으로는 승계인수의 효과가 생기는 것이 아니고 인수결정에 의하여 비로소 그 효과가 생기는 것이므로 인수결정이 있기까지는 기록표지에 승계인수인의 성명을 표시해서는 안 된다는 것이다.

(2) 심 문

인수신청이 있으면 법원은 허부의 결정을 하여야 하는데, 그 결정 전에 양쪽 당사자와 피인수신청인(제3자)을 심문하여야 한다(민소 82조 2항).

심문을 위하여는 변론기일 아닌 별도의 기일을 지정할 수도 있고 또는 변론기일에 그 제3자를 출석시켜 그 변론기일에 심문할 수도 있다. 다만 어느 경우에도 신청인의 상대방 당사자와 제3자에게는 신청서 부분 또는 말로 한 신청을 기재한 조서의 등본을 미리 송달하는 것이 바람직하다. 이를 명하는 명문규정은 없으나, 기일통지를 받은 사람이 불출석하는 경우에 대비하기 위하여 필요하다고 본다.

심문기일의 심문내용에 관하여는 조서를 작성하여야 한다. 조서양식은 [전산양식 A1660]의 심문조서를 사용하되 형식적 기재사항(민소 153조), 특히 양쪽 당사자와 피인수신청인의 출석 여부를 명시하고, 실질적 기재사항(154조)으로서 인수신청인의 진술, 피인수신청인과 상대방 당사자의 진술 등을 기재한 다음 재판장의 질문이나 이에 대한 답변을 요령 있게 정리한다. 이 경우에 “인수신청인(원고), 인수신청서 진술, 피인수신청인 20○○. ○. ○. 자 답변서 진술” 등과 같이 신청서 기타 서면을 인용하여도 좋다. 소명자료의 제출이 있을 때에는 기록에 철하면 되고 굳이 조서에 기재할 필요는 없다.

변론기일에 심문을 행한 경우에는 변론조서에 위의 사항을 기재한다. 이 경우 당사자 출석 여부 표시란은 다음 예시와 같이 한다.

원고(인수신청인)	○○○ 출 석
피고	○○○ 불출석
피인수신청인	○○○ 출 석

심문기일의 기일통지를 받은 당사자나 제3자가 정당한 이유 없이 출석하지 않은 때에는 그 사람이 신청서 등의 부분을 미리 송달받아 신청내용을

알고 있는 한 그대로 결정을 하여도 좋다.

제3자에 대한 기일통지서가 송달불능된 경우에는 물론 인수신청인에게 주소보정을 명하여야 하겠지만 끝내 송달이 되지 않는 때는 공시송달을 하고 결정을 할 수 있을 것이다.

피고의 승계인수인이 심문 당시 채무승계사실을 인정하였다면 이는 채무 승계에 관한 원고의 주장사실을 그대로 자백한 것이 되므로 그 자백이 유효하게 취소되지 않는 한 승계인수인은 그 후의 변론에서 승계인수의 전제가 된 승계사실을 다룰 수 없으며 법원도 그 자백에 구속된다(대법원 1987. 11. 10. 선고 87다카473 판결).

(3) 결 정

법원은 심문 후, 인수의 허부를 정하는 결정을 한다. 심문의 결과, 승계의 사실이 주장 자체에서 인정되지 않거나 또는 요건에 흠이 있을 때에는 인수 신청을 각하하는 결정을 한다. 그러나 소송계속 중에 소송목적의 의무의 승계가 있다는 이유로 하는 소송인수신청이 있는 경우 신청의 이유로서 주장하는 사실관계 자체에서 그 승계적격의 흠이 명백하지 않는 한 결정으로 그 신청을 인용하여야 하는 것이고, 그 승계인에 해당하는가의 여부는 피인수 신청인에 대한 청구의 당부와 관련하여 판단할 사항으로 심리한 결과 승계 사실이 인정되지 않으면 청구기각의 본안판결을 하면 되는 것이지 승계인수 신청 자체가 부적법하게 되는 것은 아니다(대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다 66691 판결).

인수를 명하는 결정의 주문 기재례는 다음과 같다.

① 교환적 전부인수의 경우에는 청구내용이 구 청구와 같은 취지의 것이기 때문에 청구취지를 따로 밝히지 아니하여도 무방하다(대법원 1976. 12. 14. 선고 76다1999 판결).

피인수신청인은 피고를 위하여 이 사건 소송을 인수한다.

② 교환적 일부인수의 경우

피인수신청인은 피고를 위하여 이 사건 소송 중 10,000,000원 및 이에 대하여 20○○. ○. ○.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원 청구 부분을 인수한다.

③ 추가적 인수의 경우

피인수신청인은 피고를 위하여 다음을 청구취지로 하여 이 사건 소송을 추가적으로 인수한다.

다 음

1. 피인수신청인은 인수신청인(원고)에게 ○○지방법원 ○○등기소 20○○. ○. ○. 접수 제○○호로 마친 ○○등기의 말소등기절차를 이행하라.
2. 소송비용은 피인수신청인의 부담으로 한다.

인수를 명하는 결정은 일응 승계적격의 사실을 인정하여 제3자를 당사자로 취급한다는 취지의 중간적 재판이기 때문에, 후에 본안판결을 할 때에 법원이 이에 구속되는 것은 아니며, 본안변론에서의 증거조사결과 승계가 없었다고 인정되면 종국판결로써 승계인수인에 대한 청구 또는 승계인수인의 청구를 기각하여야 할 것이다.

인수를 명하는 결정에 대하여는 독립하여 항고할 수 없고(대법원 1990. 9. 26. 자 90그30 결정), 종국판결에 대한 상소로 다룰 수 있을 뿐이다(민소 392조). 다만 인수신청을 기각하는 결정에 대하여는 민사소송법 439조에 의하여 통상의 항고를 할 수 있다. 항고가 있는 경우에는 물론 기록 전체를 그대로 송부할 것이 아니라 재판장이 지정하는 필요부분만을 등본하여 송부하여야 한다(재일 80-3 1책의 기록에 관하여 수개의 절차에서 동시에 소송이 계속하게 되는 때의 처리요령).

(4) 결정 후의 사무처리

인수를 명하는 결정이 있으면 기록표지에 ‘승계인수인’ 난을 만들어 그 성명과 대리인의 표시를 하여야 한다. 그 이후에는 기록상의 호칭이 ‘피인수인

청인'이 아니라 “승계인수인”이 됨을 유의하여야 한다. 다만 승계인수인 대신 “소송인수인”이라고 하여도 무방하다.

인수신청을 기각하는 결정이 있을 때는 기록상 특별한 처리를 할 필요가 없다.

4. 종전 당사자의 지위와 소송탈퇴

승계참가나 승계인수를 묻지 않고 널리 소송물의 양도가 있는 경우에 ① 피참가인이 승계의 효력을 다투거나, ② 소송물의 일부에 관하여서만 승계가 있거나, ③ 승계인수에 있어 추가적 인수의 경우에는 종전 당사자는 계속해서 그 소송에 남아 있을 필요가 있다. 위의 경우 중 ②, ③의 경우에는 종전 당사자와 새로운 당사자가 필수적 공동소송인의 관계에 서게 된다(원고와 승계참가인의 청구 사이에는 필수적 공동소송에 관한 민사소송법 67조가 적용된다는 대법원 2019. 10. 23. 선고 2012다46170 전원합의체 판결 참조). ①의 경우와 관련하여, 권리자가 누구인지 문제 되는 경우에는 독립당사자참가 소송의 형태로 보아 민사소송법 79조를 적용하고 의무자가 누구인지 문제 되는 경우에는 예비적 공동소송의 형태로 보아 민사소송법 70조를 적용하는 견해가 있고, 권리자가 문제 되는지 의무자가 문제 되는지 불문하고 독립당사자참가 소송의 형태로 보아 민사소송법 79조를 적용하는 견해가 있다.

그러나 그 밖의 경우, 즉 소송물의 전부에 관하여 승계가 있고 승계에 관한 다툼이 없는 경우에는 종전 당사자는 그 소송에 남아 있을 필요가 없게 되므로 소송에서 탈퇴할 수 있게 된다. 승계인수의 경우에는 민사소송법 82조 3항에 명문규정이 있고, 승계참가의 경우에는 독립당사자참가의 경우에 준하여 해석상 가능하다고 설명된다.

제1심에서 원고가 승소하였으나 항소심에서 원고에 대한 승계참가가 있고 원고가 적법하게 탈퇴한 경우 항소심으로서는 제1심판결을 변경하여 승계참가인의 청구에 대한 판단을 하여야 하고, 단순히 피고의 항소를 기각하

는 것은 위법하다(대법원 2004. 1. 27. 선고 2000다63639 판결).

한편 소송의 탈퇴는 승계참가가 적법한 경우에만 허용되는 것이므로, 승계참가가 부적법한 경우에는 피참가인의 소송 탈퇴는 허용되지 않고 피참가인과 상대방 사이의 소송관계가 유효하게 존속한다. 따라서 승계참가인의 참가신청이 부적법함에도 불구하고 법원이 이를 간과하여 승계참가인의 참가신청과 피참가인의 소송 탈퇴가 적법함을 전제로 승계참가인과 상대방 사이의 소송에 대해서만 판결을 하였는데 상소심에서 승계참가인의 참가신청이 부적법하다고 밝혀진 경우, 피참가인과 상대방 사이의 소송은 여전히 탈퇴 당시의 심급에 계속되어 있으므로 상소심법원은 탈퇴한 피참가인의 청구에 관하여 심리·판단할 수 없다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011다85789 판결).

탈퇴의 절차라든가 탈퇴 시의 사무처리는 독립당사자참가의 경우와 같으므로 독립당사자참가에 관한 해당부분을 참조하면 된다.

5. 참가와 인수에 의한 실체법상 효과

참가와 인수에 의한 실체법상의 효과로서, 참가와 인수가 있으면 참가 및 인수시기에 불구하고 소가 제기된 시점으로 소급하여 시효중단, 법률상의 기간 준수의 효력이 생긴다(민소 81조, 82조 3항).

한편 원고이었던 자가 탈퇴한 경우 시효중단의 효력과 관련하여 소송탈퇴는 소취하와는 성질이 다르며, 탈퇴 후 잔존하는 소송에서 내린 판결은 탈퇴자에 대하여도 효력이 미치는 점에 비추어 보면, 인수참가인의 소송목적 양수 효력이 부정되어 인수참가인에 대한 청구기각 또는 소각하 판결이 확정된 날부터(탈퇴한 때부터가 아니다) 6개월 내에 탈퇴한 원고가 다시 탈퇴 전과 같은 재판상의 청구 등을 한 때에는, 탈퇴 전에 원고가 제기한 재판상의 청구로 인하여 발생한 시효중단의 효력은 그대로 유지된다(대법원 2017. 7. 18. 선고 2016다35789 판결).

제6절 공동소송참가

1. 의 의

‘공동소송참가’라 함은 소송목적이 한쪽 당사자와 제3자에게 합일적으로 확정되어야 할 경우에 그 제3자가 계속 중의 소송에 공동소송인으로서 참가하는 것을 말하는데(민소 83조, 대법원 2001. 7. 13. 선고 2001다13013 판결), 이 경우 참가인과 피참가인 간에는 필수적 공동소송관계가 생긴다. 예컨대 주주의 1인이 주주총회결의취소의 소를 제기하고 그 소의 판결의 효력을 받을 다른 주주가 공동 원고로서 소송에 참가하는 경우, 상법 404조 1항 소정의 회사가 주주대표소송에 참가하는 경우(대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다9086 판결), 채권자대위 소송계속 중 다른 채권자가 동일한 채무자를 대위하여 동일한 채권에 대하여 채권자대위권을 행사하면서 소송에 참가하는 경우(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다30301 판결) 등이 이에 해당한다.

처음부터 여러 사람의 원고가 또는 여러 사람의 피고에 대하여 공동으로 소를 제기한 경우가 소의 고유의 주관적 병합인 데 반해서 이러한 공동소송은 소송계속 후에 후발적으로 발생하는 것이다.

여기서 ‘합일적으로 확정될 경우’라 함은 원래부터 참가인과 피참가인 간의 관계가 필수적 공동소송인의 관계에 있어야 했던 경우를 가리킨다. 다만 여기의 필수적 공동소송이 유사필수적 공동소송인 경우에 한정되는가 아니면 고유필수적 공동소송인 경우에도 적용되는가에 관하여는 견해의 대립이 있으나, 유사필수적 공동소송뿐만 아니라 고유필수적 공동소송에도 적용된다는 것이 통설이다. 따라서 고유필수적 공동소송의 공동소송인으로 원래 당사자가 되어야 할 사람이 잘못 제외되어 제기된 소도 공동소송참가에 의하여 당사자로 되면 그 하자가 치유된다.

고유필수적 공동소송의 경우 일부 탈락된 공동소송인을 추가하는 제도가

따로 마련되어 있지만(민소 68조), 공동소송참가는 민사소송법 68조에 의한 추가와는 달리 항소심에까지 허용되고(대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다9086 판결), 제3자가 이 방식에 의하여 스스로 소송에 참가하여 당사자적격의 흠을 보정할 수 있게 된다는 점에서 이 제도의 독자적 의의가 있다.

2. 요건

소송계속 중임을 요한다. 다만 공동소송참가가 신소제기의 실질을 갖기 때문에 상고심에서는 불가능하다(대법원 1961. 5. 4. 선고 4292민상853 판결).

공동소송참가인은 당사자적격을 갖추어야 한다. 공동소송참가인이 참가 이후 소송당사자가 되는 이상 당연한 요건이다.

소송의 목적이 당사자 일방과 제3자 간에 합일확정될 경우이어야 한다. 학 교법인의 이사회결의무효확인 소의 경우 승소확정판결이 났다고 하더라도 그 판결의 효력은 위 소송의 당사자 사이에서만 발생하는 것이지 대세적 효력이 있다고 볼 수는 없으므로, 이사회결의무효확인 소는 그 소송의 목적이 당사자 일방과 제3자에 대하여 합일적으로 확정될 경우가 아니어서 제3자는 공동소송참가를 할 수 없다(대법원 2001. 7. 13. 선고 2001다13013 판결).

3. 사무처리

가. 참가신청과 접수

참가신청방식에는 보조참가신청에 관한 규정이 준용된다(민소 83조 2항). 다만 공동소송참가신청은 원고 측에 참가하는 경우에는 소의 제기에 해당하는 것이기 때문에 반드시 서면에 의할 것이 필요하고 피고 측에 참가하는 경우에도 원고의 경우와의 균형상 서면에 의할 것이 필요하다고 함이 통설이다.

신청서에는 물론 참가의 취지와 이유를 명시하여야 하고(민소 72조 1항), 원고 측 공동소송참가신청서에는 심급에 따라 소장 또는 항소장에 준하는

액수의 인지를 붙여야 하며(인지 2조, 6조), 피고 측 공동소송참가신청서에는 인지를 붙이지 아니한다(인지액·편철방법예규).

원고 측 공동소송참가는 실질적으로 신소제기의 성격이 있으므로, 신청서가 접수되면 이를 민사사건으로 전산입력하고, 신청서와 관계서류는 본기록에 합철하며, 독립된 1개의 사건으로 별도의 사건번호를 부여하여야 한다. 반면에 피고 측 공동소송참가신청서가 접수되면 문건으로 전산입력하고, 신청서와 관계서류는 본기록에 가철한다(인지액·편철방법예규). 참가신청이 있으면 기록표지에 참가인의 표시를 하여야 한다.

신청서는 그 부분을 바로 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다(민소 83조, 72조 2항, 민소규 64조 2항).

나. 심 리

공동소송참가에 대하여는 기존 당사자가 이익을 할 수 없다고 함이 통설이다. 물론 법원으로는 직권으로 참가의 적부를 심사하고 요건의 흠이 있는 때에는 종국판결로 참가신청을 각하하여야 한다. 다만 요건에 흠이 있는 참가신청이 있더라도 다른 참가신청, 예컨대 보조참가신청 또는 공동소송적 보조참가신청의 요건에 해당된다고 인정할 때에는(예컨대 주주총회결의취소의 소의 출소기간이 경과한 다른 주주) 그러한 다른 참가신청으로 취급하여도 무방할 것이다.

참가가 적법하다고 인정되면 참가인과 피참가인은 필수적 공동소송인이 되므로 필수적 공동소송에 관한 민사소송법 67조가 적용된다.

제7절 소송고지

1. 의 의

‘소송고지’라 함은 소송계속 중에 당사자가 소송참가를 할 이해관계 있는 제3자에 대하여 일정한 방식에 따라서 소송계속의 사실을 통지하는 것을 말한다. 이는 제3자에게 소송계속의 사실을 알려서 피고지자에게 소송에 참가할 수 있는 기회를 줌과 동시에, 고지에 의하여 피고지자에게 그 소송의 판결의 효력(참가적 효력)을 미치게 하려는 제도이다. 예컨대 보증인이 채권자로부터 보증채무의 이행을 소구 당한 경우 주채무자에게 소송고지하면 후에 보증인이 패소 후 보증채무를 지급하고 주채무자에 대하여 구상권을 행사할 경우 주채무자가 주채무 부존재의 항변을 할 수 없다.

소송고지는 고지자의 권한일 뿐 원칙적으로 고지의무는 없다. 그러나 예외적으로 법률에 의하여 소송고지가 강제되는 경우가 있는데 ① 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기한 채권자는 채무자에게 그 소를 고지하여야 하고(민집 238조), ② 상법 403조 3항과 4항에 따른 주주대표소송을 제기한 주주는 회사에 대하여 소제기 사실을 지체 없이 고지하여야 하는 것(상법 404조 2항) 등이 그것이다.

다만 소송고지가 의무인 경우라도 소송고지가 소제기요건이거나 직권조사 사항이라고 할 수는 없다(대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145 판결).

소송고지를 할 수 있는 사람은 계속 중인 소송의 당사자인 원고·피고(당사자참가인, 승계참가·인수당사자 포함), 보조참가인 및 이들로부터 고지를 받은 사람이다.

피고지자가 될 수 있는 사람은 당사자 아닌 사람으로서 그 소송에 참가할 수 있는 제3자이다. 보조참가를 할 수 있는 사람은 물론이고(실무상으로는 이 경우가 가장 많다), 독립당사자참가, 공동소송참가 또는 권리승계참가를 할

수 있는 제3자도 포함된다.

2. 사무처리

가. 신청과 접수

소송고지를 하고자 하는 사람은 소송고지신청서와 함께 소송고지서를 필요한 통수만큼 첨부하여 제출하여야 한다.

소송고지신청서에는 사건의 표시(사건번호와 당사자의 성명)와 함께 “별첨 소송고지서와 같은 소송고지를 신청한다.”는 내용의 문구를 기재하고 신청인이 기명날인 또는 서명한다. 말로 하는 신청도 물론 가능하나 이때도 소송고지서는 동시에 제출하여야 한다. 신청에는 인지를 붙이지 아니한다(인지액·편철방법예규).

소송고지서에는 사건의 표시(사건번호와 당사자의 성명, 주소)를 기재하고 누가 고지자인지를 명시한 다음 피고지자의 성명과 주소를 명기하고, 고지의 이유와 소송의 진행정도를 기재하여야 한다(민소 85조 1항).

‘고지의 이유’에는 어떠한 소송이 계속되고 있는지를 청구취지와 원인의 요지를 기재하여 명시한 다음, 그 소송의 결과에 관하여 피고지자가 이해관계를 갖게 되는 이유를 구체적으로 표시한다.

‘소송의 진행정도’에는 현재 소송이 변론진행 중인지 여부, 변론준비절차에 들어갔는지 여부와 다음 기일의 일시 등을 표시하는 것으로 충분하다. 상소심에서 고지할 때에는 원심에서 누가 패소하여 상소하였는지를 표시하여야 한다.

소송고지신청서가 접수되면 문건으로 전산입력하고(인지액·편철방법예규), 신청서와 소송고지서 1통을 기록에 가철한다. 물론 사건번호는 따로 부여되지 아니하며 기록표지에도 아무런 표시를 할 필요가 없다.

나. 심 리

소송고지신청이 있는 경우 법원은 소송고지서의 방식 준수 여부를 조사하여 흠이 있으면 보정시켜야 하고 보정에 응하지 않을 때에는 신청을 각하한다. 이 각하 결정에 대하여는 통상의 항고가 가능하다(민소 439조).

그러나 소송고지를 할 경우인지 아닌지에 관하여는 명백한 경우가 아니면 엄격한 심사를 할 필요 없이 일응 신청에 따라 고지를 행하고, 그 요건 해당 여부는 후에 피고지자가 참가한 경우 그 허부를 결정할 때 또는 고지자와 피고지자 사이에 고지의 효과가 문제 될 때에 판단하면 될 것이다.

다. 고지의 방법

소송고지를 할 때에는 법원 명의의 고지서를 따로 작성하는 것이 아니라 고지자가 제출한 고지서를 그대로 피고지자에게 송달하여야 한다. 소송고지의 효력은 피고지자에게 적법하게 송달된 때에 비로소 생기고, 소송고지서가 송달불능이면 소송고지의 효력이 발생하지 않는다. 이 송달이 늦어진 나머지 고지서의 기재 내용이 사실과 부합하지 않게 될 경우(예컨대 신청 당시와 고지서 발송 당시 사이에 시간적 간격이 있어서 '소송의 진행정도'에 관한 기재가 사실과 부합하지 않게 될 경우)가 없도록 지체 없이 송달할 것을 요한다.

한편 고지자의 상대방 당사자에게도 고지서를 송달하여야 하는데(민소 85조 2항), 이 송달은 고지의 효력발생과는 관계가 없다.

송달에 필요한 비용(송달료)은 신청 접수 시에 따로 예납 받는 것이 원칙이다. 다만 고지자로부터 전에 예납 받아 둔 송달료가 있을 때는 그 송달료에서 지출하여도 무방하다. 고지서의 송달에 소요된 비용은 본안소송(고지자와 상대방 간)의 소송비용에는 산입되지 않고 고지자가 부담하여야 하며(따라서 송달료예규 4조, 5조의 규정에 불구하고 상대방의 예납비용에서 지출할 수 없다), 후에 피고지자가 참가하여 온 경우의 소송비용(이른바 참가비용)이 되는데 불과하다.

3. 효 과

소송고지를 받은 사람이 참가하지 않은 경우라도 민사소송법 86조(참가인에 대한 재판의 효력)의 적용에 있어서는 그가 참가할 수 있었을 때에 참가한 것으로 본다. 즉 참가하지 않았더라도 판결의 참가적 효력이 미치게 된다. 그러나 피고지자가 소송에 참가하지 않았으면 비록 위와 같이 피고지자에게 민사소송법 86조의 참가적 효력이 발생한다 하더라도 판결에는 피고지자의 이름을 표시하여서는 안 된다(대법원 1962. 4. 18. 선고 4294민상1195 판결).

소송고지제도는 소송의 결과에 대하여 이해관계를 가지는 제3자로 하여금 소송에 참가하여 그 이익을 옹호할 기회를 부여함과 아울러 고지자가 패소한 경우에는 형평의 견지에서 그 패소의 책임을 제3자에게 분담시키려는 제도로서 피고지자는 후일 고지자와의 소송에서 전소 확정판결에서의 결론의 기초가 된 사실상·법률상의 판단에 반하는 것을 주장할 수 없게 된다. 이 경우 주장할 수 없는 것은 피고지자가 참가하였다면 상대방에 대하여 ‘고지자와 공동이익’으로 주장하거나 다룰 수 있었던 사항에 한할 뿐이므로, 고지자와 피고지자 사이에서만 이해가 대립되는 사항에 대하여는 참가적 효력이 생기지 않는다(대법원 1991. 6. 25. 선고 88다카6358 판결).

소송고지의 요건이 갖추어진 경우에 그 소송고지서에 고지자가 피고지자에 대하여 채무의 이행을 청구하는 의사가 표명되어 있으면 민법 174조에 정한 시효중단사유로서의 최고의 효력이 인정된다. 또한 당해 소송이 계속 중인 동안은 최고에 의하여 권리를 행사하고 있는 상태가 지속되는 것으로 보아 민법 174조에 규정된 6월의 기간은 당해 소송이 종료된 때로부터(소송고지된 때가 아니다) 기산되는 것으로 해석하여야 한다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2009다14340 판결). 나아가 소송고지에 의한 최고는 법원의 행위를 통하여 이루어지는 것이므로 만일 법원이 소송고지서의 송달사무를 우연한 사정으로 지체하는 바람에 소송고지서의 송달 전에 시효가 완성된다면 고지자가 예상치 못한 불이익을 입게 된다는 점 등을 고려하면, 소송고지에 의한 최고

의 경우에는 민사소송법 265조를 유추적용하여 당사자가 소송고지서를 법원에 제출한 때에 시효중단의 효력이 발생한다고 봄이 상당하다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014다16494 판결).